2024년 특허·상표
판례연구논문 공모전
우수논문집

Intellectual Property
Trial and Appeal Board

03

우수상

장 설 경

# 소극적 권리범위확인심판에서 침해사실 증명책임의 소재

# 판례연구 논문 요약서

| | |
|---|---|
| 판례번호 | 특허법원 2016허4818 판결<br>특허법원 2006허2295 판결 |
| 제 목 | 소극적 권리범위확인심판에서 침해사실 증명책임의 소재 |
| 요 약 | 본 논문은 소극적 권리범위확인심판에서 누가 증명책임을 부담하는지 여부에 대해 논한다. 즉, 동 심판의 청구인이 확인대상이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음(부존재)에 대해 증명해야 하는지 또는 특허권자인 피청구인이 확인대상이 특허발명의 권리범위에 속함(존재)에 대해 증명해야 하는지에 대해 논한다.<br>우리나라와 주요국의 법리를 두루 분석한 결과, 본 논문은 피청구인인 특허권자가 확인대상이 권리범위에 속한다는 사실을 증명하게 하는 법리가 후속 침해소송과의 관계에서 더 바람직하다고 주장한다. |
| 필 요 성 | 법률요건분류설에 따른 일반적인 민사소송에서 소극적 확인의 소의 경우, 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고는 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·증명책임을 부담하는 반면, 소극적 권리범위확인심판 및 후속 심결취소소송 단계의 실무에서는 소극적 권리범위확인심판의 청구인이 권리관계의 요건사실이 존재하지 않는 점을 증명하여야 한다. 이는 현행 소극적 권리범위확인심판의 실무에서 증명책임의 분배가 현행 민사소송의 통설·판례의 증명책임의 분배원칙과 모순되는 점이라고 할 수 있다. 따라서 소극적 권리범위확인심판에서의 증명책임을 누가 부담하여야 합리적인지에 대하여 연구하려 하는 것이다. |
| 독 창 성 | 청구(주장)하는 자가 증명책임을 부담한다는 일반원칙에 따르면 청구인이 속하지 않음(비침해)을 증명하게 하는 것이 타당하다. 한편, 부존재를 증명하게 하는 것보다는 존재를 증명하게 하는 것이 더 바람직하다는 원칙에 따르면 피청구인(특허권자)이 속함(침해)을 증명하게 하는 것이 타당해 보인다. 본 논문은 소극적 권리범위확인심판이 후속 특허권 침해소송을 예방하거나 간편하게 하여야 한다는 기능을 달성한다는 측면에서 두 충돌하는 원칙 중 전자가 더 타당함을 논증하였다. |
| 파급효과 | 본 논문이 주장하는 바와 같이 소극적 권리범위확인심판에서 피청구인(특허권자)이 권리범위에 속함(침해)을 증명하게 하는 법리가 실무에서 적용되는 경우, 동 심판에서 심리된 바로 인하여 후속 침해소송의 제기가 금지되거나 혹은 동일한 대상에 대한 중복 다툼이 방지될 것이 기대된다. |

우수상

# 소극적 권리범위확인심판에서 침해사실 증명책임의 소재

특허법원 2016허4818 판결, 특허법원 2006허2295 판결

## 목 차 / Contents


1. 서 론 ····· 134
2. 특허심판에서 증명책임에 관한 현행 법리 및 문제점 특정 ····· 134
3. 미국의 Medtronic v. MFV 판결의 법리 ····· 143
4. 중국의 특허권 비침해확인소송에서의 증명책임 법리 ····· 156
5. 오스트리아의 (특허권) 소극적 권리범위 확인심판에서의증명책임 법리 ····· 160
6. 일본의 부존재(비침해) 확인소송에서의 증명책임 ····· 165
7. 영국의 (특허권) 비침해 확인제도 및 Opinion제도에서의 증명책임 법리 ·· 166
8. 독일의 확인소송의 증명책임 법리 ··· 169
9. 결 론 ····· 170

## 1 서 론

본 연구는 소극적 권리범위확인심판에서 누가 속함 또는 속하지 않음에 대하여 증명책임을 부담하는지에 대해 논한다. 즉, 동 심판의 청구인이 확인대상이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음(비침해)에 대해 증명해야 하는지 또는 특허권자인 피청구인이 특정된 확인대상이 특허발명의 권리범위에 속함(침해)에 대해 증명해야 하는지에 대해 논한다.

해당 법리에 대한 주요국의 상응 법리를 조사함에 있어서는 다른 국가에 (오스트리아 및 영국을 제외하고는) 권리범위확인심판 제도가 존재하지 않는다는 점을 감안하여, 소극적 권리범위확인심판과 대응되는 특허권 비침해확인소송 및 일반 민사소송에서의 소극적 확인소송을 조사할 것이다.

소극적 권리범위확인심판에서 특허심판원은 확인대상이 권리범위에 속하는지 여부만을 심리하는 것이 아니라, 자유실시기술의 항변, 신규성 결여의 항변 등 여타 쟁점도 심리하게 된다. 본 연구는 그 여러 쟁점에 대한 증명책임의 소재에 대하여는 논하지 않고, 권리범위에 속하는지 여부에 대한 증명책임의 소재에 대하여만 논한다. 일차적으로, 권리범위확인심판의 핵심 심판물의 증명책임의 소재에 대해 먼저 해결한 후, 그다음 단계에서 다른 부차적 심리대상의 증명책임의 소재에 대해 해결할 수 있을 것이다.

## 2 특허심판에서 증명책임에 관한 현행 법리 및 문제점 특정

### 가 증명책임의 개념

법원이 어떤 대상(소송물, 쟁점)에 법률을 적용하여 결론을 내리기 전의 과정에서, 각 당사자는 자신에게 유리한 사실을 주장하게 된다. 만약 당사자 사이에 그 사실에 대해 다툼이 있다면, 그 사실은 증거를 통해 확정되어야 하고 이러한 과정

에서 주장책임과 증명책임이 논의된다.[1)]

증명책임이란 소송상 어느 증명을 요하는 사실의 존부가 확정되지 않을 때에(진위불명), 해당 사실이 존재하지 않는 것으로 또는 존재하는 것으로 취급·판단을 받게 되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 말한다.[2)] 이러한 진위불명의 상태는 변론주의에[3)] 의하는 소송절차는 물론이고 직권탐지주의에[4)] 의하는 소송절차에서도 문제될 수 있으므로 증명책임은 모든 소송절차에 적용된다고 할 수 있다.[5)] 증명책임은 소송 과정에서 사실이 진실인지 아닌지에 대해 법원이 확신을 가지지 못하는 경우, 즉 증명이 충분하지 않을 때, 그로 인해 누가 불이익을 감수해야 하는지를 결정하는 역할을 한다.[6)] 그러므로, 증명책임에서 원·피고 중 어느 당사자가 어떠한 요건사실을 증명해야 하는지를 결정하는 증명책임의 분배는 소송절차에서 매우 중요한 요소가 된다.[7)] 요건사실이란, "실체법규에서 권리 또는 법률관계의 발생, 저지, 소멸 등의 법률효과가 생기는 요건으로 정하고 있는 것(법률요건 또는 구성요건)에 해당하는 구체적 사실을 가리킨다."[8)] 증명책임은 소송의 결과에 큰 영향을 미치므로 법적 분쟁에서 법률효과를 발생시키기 위한 요건사실이 불분명할 때, 법원이 자의적으로 판단하지 않고, 정치적 개입이나 현실적 요구에 흔들리지 않으며,

1) 전현철, "조세소송에 있어서 주장책임과 증명책임에 관한 고찰", 원광법학 제35권 제3호, 원광대학교 법학연구소, 2019, 164면("재판은 구체적 사실을 확정하고 여기에 법규를 해석·적용하여 법적 결론을 도출하는 논리적인 판단 작업이므로, 법규의 존부·해석과 더불어 구체적 사실의 확정이 필요하다. 당사자는 각자 자기에게 유리한 사실을 주장하고 당사자 사이에 다툼이 있는 사실은 증거에 의하여 확정하여야 한다. 이러한 사실 확정의 단계에서 논의되는 것이 주장책임과 증명책임이다.").

2) 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 2023, 541면.

3) 변론주의란 소송자료 즉 사실과 증거의 수집·제출의 책임을 당사자에게 맡기고, 당사자가 수집하여 제출한 소송자료만을 변론에서 다루고 재판의 기초로 삼아야 하는 입장이다. 이시윤, 앞의 책, 326면.

4) 직권탐지주의란 소송자료의 수집·제출책임을 당사자가 아닌 법원이 부담한다는 입장이다. 이시윤, 앞의 책, 326면.

5) 전현철, 앞의 논문, 178면("증명책임은 변론주의에 의하는 소송절차이든 직권탐지주의에 의하는 소송절차이든 관계없이 요구되는 것이다.").

6) 이시윤, 앞의 책, 542면("증명책임은 심리의 최종단계에 이르러도 사실주장이 진실인지 아닌지에 대해 아무런 확신이 서지 않을 때에 즉 증명이 되지 않을 때 누가 불이익을 부담하느냐의 문제이기 때문에, ...").

7) 안철상·조병구·정기상, 실무중심 요건사실: 민사소송, 서울 : 유로, 2019, 55면("증명책임의 문제에서 가장 중요한 것은 증명책임 분배의 문제이다. 즉, 어떠한 요건사실에 대하여 원·피고 어느 당사자에게 증명책임을 부담시킬 것인가의 문제이다.").

8) 안철상·조병구·정기상, 앞의 책, 24면.

법적으로 정해진 기준에 따라 공정하게 판단할 수 있도록 하는 공정성과 예측 가능성을 보장하는 중요한 법적 규범이라 할 수 있다.[9)]

## 나 주장자 증명책임 법리 = 원고증명책임 법리

로마법 시절부터 "Affirmanti incumbit probatio(주장하는 자에게 증명책임이 있다)"는 원칙이 있었으며,[10)] 이 원칙은 실무에서도 오랫동안 유지되어 왔다.[11)] 그러나 이러한 원칙은 사실문제와 법률문제를 구분하는 법학 전통과 모순되는 면을 가진다. 즉, 누가 주장을 먼저 하는가에 따라 법적 증명책임의 주체가 바뀔 수 있다는 점에서 법적 논리와 맞지 않을 수 있다.[12)] 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 Leo Rosenberg는 1923년 증명책임은 법규정의 구성에 따라 결정해야 한다는 '규범설 (Normentheorie)'을 제안하였고 이후 증명책임을 정하는 기준으로 널리 받아들여졌다.[13)]

증명책임의 분배에 관한 견해는 다양하나 현재로서는 "민사소송에서 증명책임의 분배를 법규의 구조에서 찾아야 한다는 법률요건분류설 내지는 규범설이 통

9) 백경일, "증명책임의 분배와 위험영역설에 관한 비판적 고찰 - 독일에서의 논의를 참고하여 -", 법학논총 제19권 제3호, 조선대학교 법학연구원, 2012, 263면("증명책임은 이와 같이 원고가 소구하는 법률효과를 발생시키기 위해 충족시켜야 하는 구성요건사실의 존부가 불분명한 경우에 법관이 원고 또는 피고 가운데 누구의 손을 들어줘야 하는지에 관해서 법관이 자의 또는 재량껏 판단하는 것이 아니라 일정한 형식적 기준에 따라 판단할 수 있도록 하는 규범이며, 그로 인해서 누가 불이익을 부담해야 하는지에 관해 현실적 요구나 정책적 개입에 흔들림이 없이 결단을 내릴 수 있게 해주는 규범이다.").

10) 백경일, 위의 논문, 263면("증명책임에 관해서는 전통적으로 로마법 시절부터 "Affirmanti incumbit probatio (주장하는자에게증명책임이 있다)"라는 원칙이 통용되었던 바가 있고, ...").

11) 이시윤, 앞의 책, 544면("우리 실무에서는 오래 전부터 주장하는 자가 증명책임을 진다는 이른바 주장자 증명책임설에 입각하는 경우가 많다.").

12) 백경일, 앞의 논문, 264면("이러한 원칙은 결국 누가 주장을 먼저 하는가 하는 사실문제에 따라 법적인 증명책임의 주체가 바뀔 수 있다는 모순점이 있어 사실문제와 법률문제를 분리하는 법학의 전통에 부합한다고 할 수가 없는 것이었다.").

13) 백경일, 앞의 논문, 264-265면("증명책임에 관한 기준을 정함에 있어 그 사실을 누가 먼저 주장했는가 하는 사실적 기준이 아니라 그 구성요건사실에 관련된 법규정이 어떻게 구성되어 있는가 하는 규범적 기준에 의거하도록 하기 위한 학설로서 Leo Rosenberg의 '규범설(Normentheorie)'이 이미 1923년부터 등장하여 ... 이러한 '규범설'이 제기된 이후부터 입증의 문제는 ... 견고한 규범적 문제라는 인식이 정착되기 시작했고, 소송법의 규범뿐 아니라 각 실체법의 규범역시 법관의 증거사실판단에 대해 한계를 긋는다는 점이 인식되기 시작하였다.").

설·판례로 되어 있다."[14] 법률요건분류설에 따르면, "각 당사자는 자기에게 유리한 법규의 요건사실의 존부에 대해 증명책임을 지는 것으로 분배시키고 있는 바", 즉 "권리를 주장하는 자가 권리발생에 필요한 법률요건의 존재에 대한 증명책임을 부담하고, 권리의 존재를 다투는 상대방이 권리관계 발생을 방해·저지하는데 필요한 법률요건의 존재에 대한 증명책임을 부담한다."라고 하고 있다.[15] 따라서 권리의 존재를 주장하는 당사자가 그 권리발생의 요건이 되는 권리근거 사실의 증명책임을 부담하고, 그 권리의 존재를 다투는 반대 당사자가 권리장애사실, 권리행사저지사실, 권리소멸사실의 증명책임을 부담한다.[16]

일반적으로 권리를 주장하는 자가 원고이고, 권리의 존재를 다투는 자가 피고이므로, 원고가 권리발생사실 즉 청구원인사실에 대해, 피고가 권리의 장애·소멸·저지사실 즉 항변사실에 대하여 증명책임을 지게 된다. 그러나, 권리부존재의 확인소송이나 청구이의의 소, 배당이의의 소에서는 통상의 경우와 달리 증명책임이 그 역으로 바뀌게 된다.[17] 즉 소극적 확인소송·청구이의의 소·배당이의의 소·유치권부존재확인의 소에서는 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고가 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·증명책임을 부담하는 것이다.[18] 대법원은 금전채무부존재확인소송에서[19]

14) 이시윤, 앞의 책, 544면; 안철상·조병구·정기상, 앞의 책, 55-56면("증명책임 분배에 관한 학설로서, 법률요건분류설이 통설이라고 할 수 있다. 법률요건을 정하고 있는 조문의 구조·형식에 따라 주장·증명책임을 분배를 정한다는 것이다.").

15) 조민석, "공해소송에 있어서 입증책임 - 입증경감을 중심으로 -", 토지법학 제27권 제2호, 한국토지법학회, 2011, 149면.

16) 안철상·조병구·정기상, 앞의 책, 56면("권리발생의 요건이 되는 권리근거 사실에 대하여는 그 권리의 존재를 주장하는 당사자가 증명책임을 부담하고, 그 반대의 요건이 되는 권리장애사실, 권리행사저지사실, 권리소멸사실에 대하여는 그 권리의 존재를 다투는 반대 당사자가 각각 증명책임을 부담한다고 하고 있다.").

17) 이시윤, 앞의 책, 544-546면("권리를 주장하는 자가 원고이고, 이를 다투는 자가 피고임이 보통이므로, 원고가 권리발생사실 즉 청구원인사실에 대해, 피고가 권리의 장애·소멸·저지사실 즉 항변사실에 대하여 증명책임을 지게 되는 것이 통례이다. 그러나 권리부존재의 확인소송이나 청구이의의 소, 배당이의의 소에서는 통상의 경우와 달리 증명책임이 그 역으로 바뀌게 된다.").

18) 이시윤, 앞의 책, 558면("소극적 확인소송에 있어서는 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인 사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고는 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·증명책임을 부담한다.").

19) 대법원 1998. 3. 13. 선고 97다45259 판결.

"채무자인 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고는 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·입증책임을 부담한다"고 판시한 바 있다. 또, 유치권부존재확인소송에서[20] "소극적 확인소송에 있어서는 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인 사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고는 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·증명책임을 부담한다"고 판시하였다. 나아가, 배당이의소송에서도[21] "배당이의소송에 있어서의 배당이의사유에 관한 증명책임도 일반 민사소송에서의 증명책임 분배의 원칙에 따라야 하므로, 원고가 피고의 채권이 성립하지 아니하였음을 주장하는 경우에는 피고에게 채권의 발생원인사실을 입증할 책임이 있다"고 판시하였다. 이렇듯, 우리나라 대법원 판례에서는 일반적으로 원고가 권리의 부존재를 주장하면, 그 권리의 발생원인사실의 증명책임은 상대방인 피고가 부담한다고 보고 있다.

## 다 악마의 증명

악마의 증명(라틴어: probatio diabolica, 영어: devil's proof)이란 중세 유럽에서 사용된 법적용어로 어떠한 사실이나 인과가 존재하지 않음을 증명하는 것은 불가능에 가까우므로, 존재한다고 주장하는 자가 증명해야 함을 비유적으로 표현한 말이라고 한다.[22] 있다는 것을 증명하기 위해서는 존재의 증거만 제시하면 되지만, 없다는 것을 증명하기 위해서는 모든 가능성에 대하여 증거가 없음을 증명하여야 한다. 그러므로 악마의 증명이란 "증명할 수 없는 사실"을 증명해야 하는 불합리한 증명책임인 것이다. 대법원도 이러한 불합리한 증명책임의 문제에 대하여 인정한 바 있다. 기사삭제 관련 소송에서 대법원은 "사실이 존재한다고 적극적으로 주장하는 자는 그러한 사실의 존재를 수긍할 만한 소명자료를 제시할 부담을 진다"고 설시하였다.[23] 또한 병역위반 관련 소송에서도 "양심적 병역거부를 주장하는

20) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013다99409 판결; 대법원 2018. 7. 24. 선고 2018다221553 판결.

21) 대법원 2007. 7. 12. 선고 2005다39617 판결.

22) 나무위키.

23) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다60950 판결("사실적 주장이 진실한지 아닌지를 판단함에 있어서 그것이 특정되지 아니한 기간과 공간에서의 구체화되지 아니한 사실인 경우에, 그 부존재를 증명하는 것은 사회통념상 불가능에 가까운 반면 그 사실이 존재한다고 주장·증명하는 것이 보다 용이한 것이어

피고인이 사실의 존재를 수긍할 만한 소명자료를 제시하고, 검사는 제시된 자료의 신빙성을 탄핵하는 방법으로 진정한 양심의 부존재를 증명할 수 있다"고 판시하였다.[24]

## 라 소극적 권리범위확인심판에서의 적용 및 문제점

### (1) 적극적 권리범위확인심판에서의 증명책임

특허법 제159조 제1항은 특허심판에서 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있도록 함으로써 심리원칙으로서는 직권탐지주의를, 제2항은 특허심판에서 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지는 심리할 수 없도록 함으로써 청구취지에 대하여는 당사자에게 그 처분권을 맡기고 있는바 처분권주의를[25] 각 채택하고 있다.[26] 직권탐지주의에서는 당사자가 주장 또는 증명하지 않은 사실이라도, 법원이 필요하다고 판단되면 이를 직권으로 조사하여 판결의 기초로 삼을 수 있고[27] 다툼이 있는 사실관계의 증명책임을 묻지 아니한다고 한다.[28] 이

---

서 이러한 사정은 증명책임을 다하였는지를 판단할 때 고려되어야 하는 것이므로, 의혹을 받을 일을 한 사실이 없다고 주장하는 자에 대하여 의혹을 받을 사실이 존재한다고 적극적으로 주장하는 자는 그러한 사실의 존재를 수긍할 만한 소명자료를 제시할 부담을 지고 피해자는 제시된 자료의 신빙성을 탄핵하는 방법으로 허위성의 증명을 할 수 있다.").

24) 대법원 2018. 11. 1. 선고 2016도10912 전원합의체 판결("정당한 사유가 없다는 사실은 범죄구성요건이므로 검사가 증명하여야 한다. 다만 진정한 양심의 부존재를 증명한다는 것은 마치 특정되지 않은 기간과 공간에서 구체화되지 않은 사실의 부존재를 증명하는 것과 유사하다. 위와 같은 불명확한 사실의 부존재를 증명하는 것은 사회통념상 불가능한 반면 그 존재를 주장·증명하는 것이 좀 더 쉬우므로, 이러한 사정은 검사가 증명책임을 다하였는지를 판단할 때 고려하여야 한다. 따라서 양심적 병역거부를 주장하는 피고인은 자신의 병역거부가 그에 따라 행동하지 않고서는 인격적 존재가치가 파멸되고 말 것이라는 절박하고 구체적인 양심에 따른 것이며 그 양심이 깊고 확고하며 진실한 것이라는 사실의 존재를 수긍할 만한 소명자료를 제시하고, 검사는 제시된 자료의 신빙성을 탄핵하는 방법으로 진정한 양심의 부존재를 증명할 수 있다. 이때 병역거부자가 제시해야 할 소명자료는 적어도 검사가 그에 기초하여 정당한 사유가 없다는 것을 증명하는 것이 가능할 정도로 구체성을 갖추어야 한다.").

25) 처분권주의란 절차의 개시, 심판의 대상과 범위 그리고 절차의 종결에 대하여 당사자에게 주도권을 주어 그의 처분에 맡기는 입장이다. 이시윤, 앞의 책, 317면.

26) 임병웅·윤선희, "권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정에 관한 소고", 지식재산연구 제4권 제3호, 한국지식재산연구원, 2019, 31-32면.

27) 이시윤, 앞의 책, 334면("당사자가 주장하지 않은 사실도 법원은 자기의 책임과 직권으로 수집하여 판결의 기초로 삼아야 한다").

는 우리 행정소송법은 처분권주의를 심리의 기본원칙으로 하고 있지만[29] 행정소송법 제26조의 규정에 따라 법원이 직권심리를 할 수 있는 것과 일맥상통한다.[30]

처분권주의는 소송물 결정에 관한 원칙으로, 당사자가 어떤 문제를 소송의 대상으로 삼을지 결정할 수 있는 권한에 관한 것이고, 변론주의는 소송자료 결정에 관한 원칙으로, 소송에서 어떤 사실과 증거를 사용할 것인지에 대한 권한이 당사자에게 있음을 의미한다.[31]

행정소송법 제26조의 해석에 대하여 여러 가지 견해가 있고 직권탐지주의 원칙설에 따르면 우리 행정소송의 심리는 직권탐지주의를 원칙으로 하고 있기 때문에 주장책임이 문제가 되지 않는다고 한다.[32] 그러나 다수설인 변론주의 보충설에 의하면 "행정소송도 민사소송법의 규정을 준용한다는 행정소송법 제8조 제2항의 규정에 의하여 변론주의를 원칙으로 하면서도 법원이 증거가 더 보충될 필요가 있다고 판단하는 경우에 당사자가 제시하는 주장 및 증거의 범위를 넘어서 직권으로 증거를 조사할 수 있고"[33] 이는 대법원의 여러 판례를 통하여서도 확인할 수 있다.[34]

---

28) 정하중, "행정소송에 있어서 직권탐지주의와 입증책임", 고려법학 제64호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 208면("직권탐지주의하에서는 법관은 판결에 의미있는 사실의 확인을 스스로 행하며, 다툼이 되고 있는 사실관계에 대하여 누가 입증을 하여야 하는지를 묻지 않는다.")

29) 정하중, 앞의 논문 209면.

30) 행정소송법 제26조("법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다.").

31) 최선웅, "행정소송에서의 변론주의와 직권탐지주의: 행정소송법 제26조를 중심으로", 서울대학교 법학박사학위논문, 2004, 59면("처분권주의는 소송물 결정에 관한 원칙이고 변론주의는 그 바탕이 되는 소송자료 결정에 관한 원칙이 라고 할 수 있으므로 일반적으로 구별하여 쓴다.").

32) 최선웅, 위의 논문, 193면("이 설에 의하면 , 행정소송법 제26조 규정자체를 놓고 보면 행정소송에 있어서는 변론주의가 배제되고 민사소송과 달리 주장책임의 개념은 인정되지 않고 객관적 입증책임의 관념만을 인정할 뿐이라고 한다.").

33) 정차호, "특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임", 행정법연구 제36호, 행정법이론실무학회, 2013, 151면.

34) 대법원 1994. 10. 11. 선고 94누4820 판결; 대법원 2020. 9. 24. 선고 2017두497 판결("행정소송법 제26조는 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다고 규정하고 있지만, 이는 행정소송의 특수성에 연유하는 당사자주의, 변론주의에 대한 일부 예외규정일 뿐 법원이 아무런 제한 없이 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있는 것은 아니고, 일건 기록에 현출되어 있는 사항에 관하여서만 직권으로 증거조사를 하고 이를 기초로 하여 판단할 수 있을 따름이고, 그것도 법원이 필요하다고 인정할 때에 한하여 청구의 범위 내에서 증거조사를 하고 판단할 수 있을 뿐이다" )

따라서 특별행정심판인 특허심판에서도 변론주의를 원칙으로 하고 있기 때문에 주장책임 및 증명책임의 문제는 여전히 발생하고 있다. 심판의 기초가 되는 사실이 다툼이 있을 때 일방 당사자의 불이익은 여전히 문제되는 것이고, 당사자는 자신에게 불리한 결과를 방지하기 위하여 일반소송과 마찬가지로 증명책임을 부담해야 한다.[35]

일반 행정소송은 민원인과 행정청 사이의 이견을 대상으로 하지만, 권리범위확인심판은 ① 특허권자와 권리범위확인심판 청구인의 양 당사자 사이의 다툼을 대상으로 하는 것이어서 일반 민사소송의 성격을 강하게 가지는 점 및 ② 많은 경우, 대상 특허를 매개로 민사소송(특허권침해소송)이 병행 진행되고, 양 소송에서 심리되는 바가 실질적으로 동일할 수 있다는 점 등을 고려하면,[36] 민사소송법의 기본이론을 준용하는 원칙에 따라 권리범위확인심판 및 후속 심결취소소송 단계에서도 민사소송법의 증명책임 원칙이 적용되어야 한다. 민사소송법상 증명책임의 통설인 법률요건분류설을 특허심판에 적용하면, 적극적 권리범위확인심판에서 특허권 침해사실에 대한 증명책임은 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자에게 있고, 판례에서도 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 증명책임은 청구인에게 있다고 보고 있다.[37] 그 점에 대하여 이견이 있기 어렵다. 다만, 소극적 권리범위확인심판에서의 증명책임에 대하여는 이견이 있을 수 있고, (아래에서 자세히 살펴보는 바와 같이) 각 국가별로 다른 법리를 적용하고 있다.

### (2) 특허법원 2016허4818 판결

이 사건 피고는 원고(특허권자)를 상대로, “확인대상발명은 이 사건 제1항 및 제5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속하지 않는다”라고 주장하면서 소극적 권리범

35) 이미옥, “특허사건의 주장·입증책임”, 재산법연구 제27권 제3호, 한국재산법학회, 2011, 658-659면 (“심판의 기초가 되는 사실에 대하여 진위불명이 되는 경우 이에 대한 일방 당사자의 불이익은 여전히 문제되는 것이므로 당사자로서는 자신에게 불이익한 결과를 회피하기 위하여 사실상 심결취소소송에서의 입증책임의 분배에 관한 통설인 법률요건분류설의 내용에 따라 입증활동을 할 수밖에 없다.”).

36) 정차호, 앞의 논문, 153면.

37) 특허법원 2007. 1. 18. 선고 2006허6327 판결(“적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 청구인에게 있다.”).

위확인심판을 청구하였다.[38] 특허심판원은 "확인대상발명은 이 사건 제1항 및 제5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다"는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이후 특허권자는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 원고의 청구를 기각하였다. 특허법원은 "이 사건 심판청구인인 피고는 확인대상발명의 결정다형이 이 사건 특허발명의 결정다형과 동일하지 않은 사실을 입증할 책임이 있을 뿐이지 …"라고 판시하였다.

이 사건에서 특허법원은 원고(특허권자)의 청구를 기각하였지만, 대상 특허발명이 확인대상과 동일하지 않음(속하지 않음)의 증명책임은 특허권자가 아닌 소극적 권리범위확인심판의 청구인(침해염려자)가 부담한다고 판단하였다.

### 마 특허법원 2006허2295 판결

이 사건 피고는 원고(특허권자)를 상대로 확인대상이 대상 특허발명과 그 구성 및 효과가 서로 다르다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상이 대상 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 피고의 청구를 인용하였다.[39] 그 후 특허권자는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 피고가 아무런 주장·증명을 하지 아니하였으므로 이 사건 심결은 부적법하다고 판단하여 이 사건 심결을 취소하였다.[40] 이 사건에서도 특허법원은 "피고는 심판청구인으로서 확인대상발명이 이 사건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니하는 사유에 대하여 주장·입증할 책임이 있음에도 불구하고…"라고 판시하면서 확인대상발명이 등록발명의 권리범위에 속하지 않음(비침해)에 대한 증명책임은 소극적 권리범위확인심판의 청구인에게 있다고 판단하였다.

38) 특허심판원 2016. 4. 27.자 2015당1464 심결.

39) 특허심판원 2006. 1. 31.자 2004당2458 심결.

40) "피고는 심판청구인으로서 확인대상발명이 이 사건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니하는 사유에 대하여 주장·입증할 책임이 있음에도 불구하고, 이 사건 변론 종결시까지 그 사유에 관하여 아무런 주장·입증을 하지 아니하였으므로, 이 사건 심결은 더 나아가 살필 것 없이 부적법하다."

### 바 문제점

위에서 살펴본 대법원의 금전채무부존재확인소송,[41] 유치권부존재확인소송,[42] 배당이의소송에서[43] 대법원은 원고(채무자)가 해당 사실의 부존재를 주장하기만 하면, 피고(채권자)가 해당 사실의 존재를 증명해야 한다고 설시하였다. 그러한 증명책임의 분배원칙을 소극적 권리범위확인심판에 적용하면 청구인(침해염려자)이 속하지 않음(비침해)의 사실을 주장하기만 하면, 피청구인(특허권자)가 속함(침해)의 사실을 증명해야 할 것으로 보인다. 그러나, 그러한 대법원 판결들에도 불구하고 위 두 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판의 청구인이 속하지 않음(비침해)의 사실을 증명해야 한다고 설시하였다. 본 논문은 이러한 충돌 또는 모순을 해결하는 것을 목적으로 한다. 그 해결을 위하여 이하에서 주요국의 상응 법리를 분석한다.

## 3 미국의 Medtronic v. MFV 판결의 법리

미국은 특허권 비침해확인소송에서 침해 또는 비침해의 증명책임을 누구에게 부담시켜야 하는지에 대하여 다툼이 있었고, 연방대법원이 *Medtronic v. MFV* 사건에서 특허권자가 침해를 증명해야 한다는 법리를 제시하였다.[44] 이하, 해당 사건에 대하여 상세히 살핀다.

### 가 사실관계

MFV Family Ventures(이하 MFV사)는 이식형 심장자극기(implantable heart stimulator) 특허의 특허권자이다. 1991년, MFV사는 Eliy Lilly(이하

41) 대법원 1998. 3. 13. 선고 97다45259 판결.
42) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013다99409 판결; 대법원 2018. 7. 24. 선고 2018다221553 판결.
43) 대법원 2007. 7. 12. 선고 2005다39617 판결.
44) Medtronic Inc. v. MFV Family Ventures LLC 134 S.Ct. 843 (2014).

Lilly사)와 해당 특허에 대한 전용실시계약을 체결하였다. 이후 Lilly사는 해당 심장자극기 특허발명의 실시와 관련하여 Medtronic사와 재실시(sublicense)계약을 체결했다.[45] 해당 재실시계약에 의하면, MFV사 또는 Lilly사가 새로운 Medtronic사 제품이 대상 특허의 권리를 침해했다고 판단하는 경우 Lilly사가 Medtronic사에 침해를 주장하는 통지를 발송할 것을 약정하였다.[46] 또한, Medtronic사는 당사의 새 제품이 MFV사의 특허권을 침해한다는 통지를 받았을 때, 두 가지 선택이 있는데 미납실시료를 지불하거나 실시료를 지불하는 동시에 확인소송을 통하여 MFV사의 특허권의 유효성 및 집행 가능성에 대해 이의를 제기할 권리가 있다.[47] 만약 Medtronic사가 약정을 어기고 실시료를 지불하지 않을 시, MFV사는 실시계약을 해제할 수 있고 침해소송을 제기할 수도 있다.[48]

2004년, Boston Scientific사의 100% 자회사인 Guidant사는 Lilly사의 전용실시권을 승계받았다.[49] 2006년, MFV사, Guidant사 및 Medtronic사는 분쟁해결의 절차를 수정한 협정인 소위 소송유예협정(Litigation Tolling Agreement,[50] 이하 LTA)을 체결하였다.[51] LTA는 MFV사가 보유한 '19 특허'의 범위, 타당성 및 집행 가능성에 관하여 당사자들 간에 실제 분쟁이 존재한다고 명시적으로 인정하였다.[52] Medtronic사는 신제품 출시마다 확인소송을 제기하는 번거로움과 비용을 원하지 않아 LTA를 체결하였다.[53] LTA에 의하면, Medtronic사가 침해서면통

45) *Id.* at 846; 2013 WL3935883 (U.S.) Brief for Petitioner., July 26, 2013, at 9.

46) 2013 WL3935883 (U.S.) Brief for Petitioner., July 26, 2013, at 9.

47) *Id.* at 9-10 ("Upon receipt of such a notice, Medtronic had the right to pay the demanded royalties under protest and to bring a 'Declaratory Judgment action' challenging 'the validity and enforceability of any patent under the MFV license, ...").

48) Medtronic Inc. v. MFV Family Ventures LLC 134 S.Ct. 843, 846-847 (2014).

49) *Id.* at 10; Medtronic, Inc. v. Bos. Scientific Corp., 777 F. Supp. 2d 750, 758 (D. Del. 2011).

50) A tolling agreement is a written agreement, signed by both sides to a potential lawsuit, that suspends the statute of limitations for an agreed amount of time. 〈https://www.lewitthackman.com/for-whom-the-claim-tolls-5-reasons-to-consider-a-tolling-agreement-before-filing-a-lawsuit/〉.

51) 2013 WL3935883 (U.S.) Brief for Petitioner, July 26, 2013, at 10.

52) *Id.* at 9.

53) 2013 WL5172001 (U.S.), Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, September 16, 2013, at 9.

지를 받은 후, 확인소송을 통하여 침해주장에 대하여 이의를 제기하기로 선택한 경우, 쟁점실시료를 위탁계정(escrow account)에 예치한 후, 확인소송 승소 당사자에게 쟁점실시료를 분배하기로 약정하였다.[54]

## 나 쟁점

2007년, MFV사는 Medtronic사에게 귀사의 7개의 신제품이 당사의 2개 특허권을 침해한다고 통지하였다. Medtronic사는 해당 제품이 대상 특허권의 권리범위를 벗어나거나 대상 특허가 무효이기 때문에 MFV사의 특허권을 침해하지 않는다고 주장하였다.[55] Medtronic사는 결국 델라웨어 연방지방법원에 비침해확인소송을 제기하여 특허권 비침해, 특허무효 및 집행불가(unenforceability) 확인을 청구하였다. Medtronic사는 MFV사와 체결한 LTA 약정에 따라 모든 관련 실시료를 위탁계정에 예치하였다.[56] Medtronic사가 확인소송을 제기할 시 특허실시계약이 여전히 유효하기 때문에 MFV사는 침해주장 반소 청구를 할 수가 없게 되었다.[57]

## 다 양당사자 주장 및 논거

### (1) Medtronic사의 주장 및 논거

Medtronic사는 확인소송의 증명책임과 관련하여 다음과 같이 주장하였다. 첫째, 민사소송에서 증명책임은 실체법에 따라 결정되며, 확인소송으로 인해 당사자의 명목상 지위가 전환되더라도 증명책임은 바뀌지 않는다;[58] 둘째, 연방 특허법은 특허권자에게 피소된 제품이 특허권을 침해한다는 사실을 증명할 책임을 부과한

54) *Id.* at 10.

55) Medtronic Inc v. MFV Family Ventures LLC 134 S.Ct. 843, 847 (2014).

56) Medtronic, Inc. v. Bos. Scientific Corp., 777 F. Supp. 2d 750, 759 (D. Del. 2011).

57) Medtronic, Inc. v. Bos. Scientific Corp. 695 F.3d 1266, 1273 (Fed. Cir. 2012), cert. granted, 133 S. Ct. 2393 (May 20, 2013).

58) 2013 WL5666595 (U.S.), Reply Brief for Petitioner, October 16, 2013, at 18-31.

다.[59] 그러므로 비침해확인소송에서 증명책임은 특허권자에게 있다는 것이다.

Medtronic사는 비침해확인소송에서 증명책임을 원고에게 전환하는 것은 확인소송의 취지 및 목적과도[60] 어긋나는 것이라고 주장하면서 2가지 이유를 제시하였다. 하나는 비침해확인소송은 책임의 위협을 받는 당사자가 책임면제의 확인을 구하는 소송인데 상대방이 부담하여야 할 증명책임까지 부담하여야 한다면 확인소송을 활용할 가능성이 적어서 확인소송의 유용성이 훼손된다. 다른 하나는 판례 및 연방규칙에 따라 확인소송에서 결정된 쟁점은 추가 소송에서 다시 다투어지지 않으나, 추가 소송에서 증명책임이 상대방에게로 전환된 경우는 다시 다투어질 수 있으므로 확인소송의 최종성(finality)이 훼손된다.[61]

Medtronic사는 MFV사가 근거로 제시한 *Schaffer* 판결에 대하여도 논박하였다. 그 판결에 따라 원고에게 증명책임을 부담하게 하는 "통상적인 기본규칙(ordinary default rule)"을 적용하여야 한다는[62] 주장은 타당하지 않으며 *Schaffer* 판결의 기본규칙은 확인소송에서 단순하게 적용될 수 없고 본 사건과 같이 확인소송 절차에서 당사자의 명목상 역할이 전환되는 경우에는 증명책임 배분이 변경되지 않는다는 것이다. 또한, MFV사는 본 사건이 비침해확인소송이 아니라 비청구범위(non-claim coverage) 에 대한 확인소송이라고 주장하나[63] MFV

59) *Id.* at 34-47.

60) to provide "an immediate and definitive determination of the legal rights of the parties."

61) Restatement (Second) of Judgments § 28 (1982), ("Although an issue is actually litigated and determined by a valid and final judgment, and the determination is essential to the judgment, relitigation of the issue in a subsequent action between the parties is not precluded in the following circumstances: ... (4) The party against whom preclusion is sought had a significantly heavier burden of persuasion with respect to the issue in the initial action than in the subsequent action; the burden has shifted to his adversary; or the adversary has a significantly heavier burden than he had in the first action; or ...").

62) Schaffer v. Weast, 546 U.S. 49, 55 (2005) ("the normal rule [is to] allocat[e] the burden to the party seeking relief.").

63) 2013 WL5172001 (U.S.), Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, September 16, 2013, at 37 ("There is a significant difference between a DJ action for non-infringement and a DJ action for non-claim coverage. In the former, the patentee must counterclaim for infringement since it arises from the same 'transaction or occurrence' as the DJ claim. Fed. R. Civ. P. 13(a)(1)(A). In contrast, in the latter, the patentee cannot counterclaim for infringement since the plaintiff/licensee is not an infringer (because of its license).").

사는 Medtronic사가 만약 피소된 제품들에 대한 실시료 지급을 거부했으면 특허권 침해소송을 제기했을 것이라고 인정하므로[64] 구제방식을 제외하고, 이 소송의 쟁점은 Medtronic사가 실시료 지불을 거부했다면 MFV사가 제기했을 침해소송에서 청구할 쟁점과 완전히 동일하므로 특허법 규정에 따라 특허권자가 침해를 입증해야 한다는 것이다.[65]

특히, 균등침해에 대한 증명책임과 관련하여, Medtronic사는 다음과 같이 주장하였다. 첫째, 비침해확인소송의 원고에게 증명책임을 부담하는 법리는 그 원고로 하여금 균등론을 포함한 어떠한 적용 가능한 이론 하에서도 침해에 대응하는 반증을 하기 어려운 처지에 놓이게 한다. 실용성과 효율성 면에서 보면 원고에게 균등침해의 침해이론을 예상하고 반박하도록 하는 것보다 특허권자에게 그러한 침해이론을 제기하고 명확하게 설명하게 하는 것이 타당하다.[66] 둘째, MFV사가 쟁점이 침해가 아닌 권리범위(claim coverage)라고 주장하는 바가 맞다고 하더라도 이는 단지 용어상의 차이일 뿐,[67] 청구항 구성, 문언침해, 균등침해 및 기타 사항에 대하여는 모두 특허법을 따라야 한다.[68]

### (2) MFV사의 주장 및 논거

'침해'의 정의에 따라 특허권을 침해하지 않는 실시권자는 침해자가 될 수 없다.[69]

---

64) *Id.* at 48 ("Alternatively, it could have chosen not to pay the royalties ("although it would have subjected itself to a suit for infringement.").

65) 2013 WL5666595 (U.S.), Reply Brief for Petitioner, October 16, 2013, at 2 & 7.

66) Brief for Petitioner, 2013 WL 3935883 (U.S.) (Appellate Brief), July 26, 2013, at 44-45 ("The Federal Circuit's rule places infringers in the particularly difficult position of disproving infringement under any possible theory, including theories under the doctrine of equivalents, … Practicality and efficiency favor requiring the patentee to raise and articulate such infringement theories, rather than requiring the accused infringer to anticipate and refute them.").

67) Reply Brief for Petitioner (Appellate Petition, Motion and Filing), 2013 WL 5666595 (U.S.), October 16, 2013, at 8 ("In any event, even if MFV were correct that the issue here is "claim coverage" rather than infringement, the distinction is purely semantic.").

68) *Id.* at 8 ("Either way, the answer turns on federal patent law governing claim construction, literal infringement, the doctrine of equivalents, and other matters.").

69) 35 U.S.C. §271(a) ("whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention…during the term of the patent therefor, infringes the patent.").

그리고 Medtronic사에게 실시권이 부여되었기 때문에 MFV사는 Medtronic사가 특허권 침해자라고 주장할 근거가 없고 '침해'라는 용어가 특허권 실시에서 사용되는 경우, 특허실시권자는 침해자가 될 수 없다.[70]

또한 증명책임과 관련하여 "구제를 청구하는 당사자가 증명책임을 부담하는 통상적인 기본규칙"이 있는데 통상적인 그 규칙이 모든 사건을 해결하지는 못하지만 대부분의 사건을 확실하게 해결하며 Medtronic사가 주장하는 바와 같이 소송 시작 단계에서 상대방 당사자에게 증명책임을 부담하게 하는 것은 극히 드문 경우라는 것이다. 침해소송에서 특허권자가 침해에 대한 증명책임을 부담하는 것은 특허권자이기 때문이 아니라 침해를 주장하고 그러한 침해에 대한 구제(금지명령, 손해배상, 고의적 침해)를 청구하기 때문에 침해를 증명해야 하는 것이다.[71] 그러므로, 특허권자가 침해에 대한 구제를 청구하고 있는지 여부가 중요하며 구제를 청구하는 경우 특허권자가 침해 사실을 증명해야 할 책임이 있고 구제를 청구하는 것이 아니라면 특허권자에게 침해에 대한 증명책임을 부담하게 할 이유가 없다는 것이다. 따라서 실시권자가 특허권자를 상대로 제기한 확인소송에서 특허권실시계약이 유효하기 때문에 특허권자가 침해에 대한 반소를 제기할 수 없어서 특허권자가 구제를 청구하지 않는 경우, 청구범위에 대한 증명책임은 일반적인 기본규칙(구제를 청구하는 당사자가 증명책임을 부담하는 경우)에 따라야 한다는 것이다.[72]

균등침해의 증명책임과 관련하여, MFV사는 다음과 같이 주장하였다. 첫째, 1심 지방법원은 '비실질적 차이(insubstantial differences)' 테스트가 균등침해를 증명하는 한 요소임을 인정하지 않는 오류를 범하였다.[73] Warner-Jenkinson

70) 2013 WL5172001 (U.S.), Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, September 16, 2013, at 6-7.

71) 2013 WL5172001 (U.S.), Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, September 16, 2013, at 23 ("Patentees asserting infringement have to prove infringement, not because they are patentees, but because they are asserting infringement (and seeking relief based on this infringement).").

72) *Id.* at 26-27 ("If there is an infringement counterclaim (both parties are seeking relief), it is an inverted infringement suit and the patentee has the burden. However, if a counterclaim is precluded (by a license), the normal default rule applies and the party seeking relief (the licensee) bears the burden.").

73) Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, 2013 WL 5172001 (U.S.) (Appellate Brief), September 16, 2013, at 14 ("The district court also erred by not recognizing that

CAFC 전원합의체 판결에서 비실질적 차이 테스트를 제시하였는데, CAFC는 원고 특허권자가 증거우위의 원칙에 따라 균등침해를 증명해야 한다고 설시하였다.[74] 둘째, MFV사의 '부정적 증명(prove a negative)'이 현실적으로 어렵다는 주장에는 다음과 같이 대응하였다. 특허권의 문언침해 또는 균등침해를 증명하기 위해서는 구성요소완비의 원칙(all elements rule 또는 all limitations rule)에 따라 피고제품이 대상 특허발명의 모든 요소를 갖추고 있음을 증명하여야 한다. 그러나 비침해를 증명하기 위해서는 청구항의 구성요소 중 하나의 요소만이라도 실시하지 않았음을 증명하면 된다. *Amstar v. Envirotech* 판결에 따르면 "청구항의 요소가 사건 쟁점제품 또는 공정에서 누락된 경우 비침해가 입증된다."[75] 다시 말하면, 피고 제품의 구성요소와 대상 특허발명의 구성요소가 모두 동일하여야만 침해가 증명되고 비침해는 하나의 요소만 달라도 증명이 되므로 비침해 증명이 더 어렵지 않고 오히려 더 쉽다는 의견이다.

### (3) 미국정부의 주장(Medtronic사 지지)

특허권 침해를 증명하려면 특허권자는 청구항이 특정하는 모든 요소가 피고 제품 또는 공정에서 문언적으로 정확하게 또는 실질적으로 균등하게 적용되는 점을 증명하여야 한다. 따라서, 특허권자가 문언침해를 주장하든 균등침해를 주장하든 구분없이 대상 특허발명이 피고 제품과 구성요소 별로 동일 또는 균등하다는 것을 증명하여야 한다.[76]

---

the "insubstantial differences" test was a recognized test for proof of doctrine of equivalents infringement (claim coverage).").

74) Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F.3d 1512, 1561 (Fed. Cir. 1995) ("Hilton Davis must prove infringement under the doctrine of equivalents by a preponderance of the legal evidence.").

75) Amstar Corp. v. Envirotech Corp., 730 F.2d 1476, 1484 (Fed. Cir. 1984) ("To prove infringement of a patent claim, it is necessary to show that the accused device has each element recited in the claim, either literally or by equivalents. This rule is known as the 'all elements' or 'all limitations' rule. To prove non-infringement, however, it is only necessary to show the absence of any one element.").

76) Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioner, 2013 WL 3990879 (U.S.) (Appellate Brief), August 2, 2013, at 16 ("To prove infringement of a patent, the patent holder must make an affirmative showing that 'every limitation set forth in a claim [is] found in an accused product or process exactly or by a substantial equivalent.'

### (4) 미국지식재산소유권자협회의[77] 주장(MFV사 지지)

대상 판례는 특허권자가 실시권자에게 침해주장을 할 수 없는 경우로, 구제를 청구하는 당사자가 증명책임을 부담한다는 잘 정립된 규칙에 따라 특허권 비침해확인을 청구하는 Medtronic사가 증명책임을 부담하여야 한다.[78]

## 라 법원의 판단

1심법원인 델라웨어 연방지방법원은 *Under Sea v. Dacor* 판결을[79] 인용하며, 비록 MFV사가 본 사건의 피고이지만, 특허권자이므로 "침해를 증명할 책임을 부담한다"고 설시한 후,[80] MFV사가 문언침해와 균등침해 모두를 증명하지 못하였다고 판시하였다.[81]

2심에서 연방관할항소법원(CAFC)은 증명책임의 소재에 대해 1심 법원과는 반대의 법리를 제시하였으며 확인소송의 원고인 Medtronic사가 비침해를 증명할 책

---

Becton Dickinson & Co. v. C.R. Bard, Inc.,922 F.2d 792, 796 (Fed. Cir. 1990). Accordingly, regardless of whether the patent holder asserts literal infringement or relies on the doctrine of equivalents, it must demonstrate how each limitation of the relevant claim maps onto the accused product. See Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.,520 U.S. 17, 29 (1997)( "[T]he doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole."); Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.,54 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir.)(for literal infringement, "every limitation set forth in a claim must be found in an accused product, exactly"), cert. denied, 516 U.S. 987 (1995).").

77) Intellectual Property Owners Association, IPO.

78) Brief of Intellectual Property Owners Association in Support of Respondents, 2013 WL 534857, at 6-7.

79) Under Sea Industries, Inc. v. Dacor Corp., 833 F.2d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1987) ("The burden always is on the patentee to show infringement.").

80) Medtronic, Inc. v. Boston Scientific Corp., 777 F.Supp.2d 750, 766 (Del. 2011); Under Sea Industries, Inc. v. Dacor Corp., 833 F.2d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1987) ("The burden always is on the patentee to show infringement").

81) Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures 134 S.Ct. 843, 847 (2014) ("After a bench trial, the court found that Mirowski had not proved infringement, either directly or under the doctrine of equivalents. And since Mirowski, the patentee, bore the burden of proof, it lost.").

임을 부담한다고 설시하였다. CAFC는 통상적으로 침해혐의자가 아닌 특허권자가 침해에 대한 증명책임을 부담하고, 특허권자가 "반소인 확인소송의 피고"인 경우에도 그 책임이 '전환(shift)'되지 않는다는 점을 인정하였다.[82] 그럼에도 불구하고 CAFC는 특허권자가 확인소송의 피고이고, MFV사처럼 특허권자가 "실시계약의 지속적 유효"에 의하여 "침해에 대한 반소"를 주장할 수 없는 경우에는 다른 규정이 적용된다고 설시하였다.[83]

특허소송에서 증명책임의 중요성을 고려하여 미국연방대법원은 Medtronic사의 상고신청을 허용하였다.[84] 연방대법원은 최종적으로 CAFC의 판결을 뒤집었다. 연방대법원은 확인소송에서 실시권자는 설득(persuasion)의 책임을 부담하지 않는다고 판시하였다.[85] 이하, 연방대법원의 판결을 상세하게 분석한다.

### (1) 판례법에 의한 논리

연방대법원은 특허권자에게 침해 설득의 책임을 부담한다는 결론은 3개 측면에서 판례들에 의해 강력하게 뒷받침한다고 설시하였다. 첫째, 특허권자는 통상적으로 침해에 대한 증명책임을 부담한다. 침해에 대한 증명책임은 일반적으로 특허권자에게 있다는 점은 잘 확립되어 있다. 둘째, 확인소송은 절차적 소송일 뿐 실체적 권리를 변경하지 않는다. 셋째, 증명책임은 소송에 있어서 실질적인 문제이며 증명책임의 배분은 실체법의 규칙이고 증명책임은 원고 청구권의 실질의 일부이며 단순한 절차 형태로 볼 수 없다.[86]

### (2) 실무적 요소

연방대법원은 세 가지 실무적인 요소들도 고려하여 그러한 결론이 도출된다고 설명하였다. 첫째, 소송의 형식에 따라 증명책임을 전환하는 것은 후속소송에 불확실성을 야기할 수 있는데 일반적인 침해소송과 다른 증명책임은 확인소송의 기능

82) Medtronic, 695 F.3d at 1272.

83) *Id.* at 1274.

84) Medtronic, 134 S.Ct. at 847.

85) *Id.* at 843 ("Holdings: The Supreme Court, Justice Breyer, held that: licensee did not have burden of persuasion in the declaratory judgment action.").

86) *Id.* at 849.

을 상실하게 한다는 것이다. 침해혐의자가 결정적 증거를 제시하지 못하여 비침해를 증명하지 못하여 확인소송에서 패소한다면, 침해혐의자는 동일한 침해행위를 계속할 수 있고, 특허권자가 침해소송을 제기하게 하고 특허권자가 결정적 증거를 제시하지 못하여 침해를 증명하지 못하여 침해소송에서 패소할 수 있다. 따라서, 양측은 침해 관련 소송에서 모두 패소할 수 있고, 침해를 미정으로 남겨두게 되어, 대상 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있는지를 알고자 하는 다른 사람들 사이에 불확실성을 야기할 수 있다. [87]

둘째, 복잡한 특허는 많은 발명의 설명과 청구항을 포함할 수 있고 특허권자는 침해혐의자보다 우월한 지위에 있으며, 제품 (또는 공정)이 침해대상 특허권을 어떻게 침해하는지를 알고 증명할 수 있다. 그러나, 특허권자가 그렇게 하기 전까지 침해혐의자는 확인소송에서 생각할 수 있는 모든 침해이론을 부정하기 위해 암흑 속에서 일해야 할 수 있다.[88]

셋째, 증명책임의 전환은 특허권의 권리범위에 도전하는 사람으로 하여금 권리를 포기하는 것과 위험을 감수하는 것 사이의 선택을 하도록 하고 이는 이러한 '딜레마'를 개선하려는 확인소송법의 목적과 조화되기 어렵다는 것이다.[89] 이러한 논리는 허가특허연계제도에서 특허권에 도전하고자 하는 제네릭 또는 바이오시밀러에게 환영받을 것이라고 생각된다.

87) *Id.* at 849-850 ("To shift the burden depending upon the form of the action could create postlitigation uncertainty about the scope of the patent. Suppose the evidence is inconclusive, and an alleged infringer loses his declaratory judgment action because he failed to prove noninfringement. The alleged infringer, or others, might continue to engage in the same allegedly infringing behavior, leaving it to the patentee to bring an infringement action. If the burden shifts, the patentee might *lose* that action because, the evidence being inconclusive, he failed to prove infringement. So, both sides might lose as to infringement, leaving the infringement question undecided, creating uncertainty among the parties and others who seek to know just what products and processes they are free to use.").

88) *Id.* at 850 ("A complex patent can contain many pages of claims and limitations. A patent holder is in a better position than an alleged infringer to know, and to be able to point out, just where, how, and why a product (or process) infringes a claim of that patent. Until he does so, however, the alleged infringer may have to work in the dark, seeking, in his declaratory judgment complaint, to negate every conceivable infringement theory.").

89) *Id.* at 850.

### (3) 반대의견 반박

연방대법원은 반대의견이 설득력이 부족하다고 지적하면서 다음과 같이 설명하였다. 첫째, 원고에게 증명책임을 부담하게 하는 *Schaffer* 판결은[90] 확인소송 판례가 아니고, 기본적인 증명책임 규칙(주장자가 증명)에 대한 예외도 다음과 같이 설시하였다. 청구의 요소가 "공정하게 반대편의 항변으로 확정될 수 있는 경우, 증명책임은 피고들에게 이동될 수 있다"; "공정성을 고려한 통상적인 규칙은 소송 상대방이 인지하고 있는 범위 내에서의 사실에 대한 증명책임을 소송 당사자에게 부담하지 않는다." 이러한 이유들 때문에, 본 사건과 같은 확인소송은 *Schaffer* 판결에서 말하는 기본적인 증명책임 규칙에 대한 예외에 해당하는 것이다.[91] 둘째, CAFC가 특허권자의 침해반소청구를 배제하는 상황을 제한했다는 그 자체만으로 그 판결이 법적으로 정당하다는 것을 보여줄 수 없다.[92] 일각에서는 특허실시계약이 유효하고 원고가 침해행위를 아직 실시하지 않았다는 사실만으로 피고가 확인소송에서 반소를 제기하는 것을 배제하는 것은 아니라는 견해도 있다.[93] Medtronic사가 특허실시계약이 유효함에도 비침해확인소송을 제기할 수 있듯이 MFV사도 침해소송을 제기할 수도 있고, Medtronic사가 제기한 비침해확인소송에서 침해의 반소를 할 수 있다는 것이다.[94] 셋째, 법원의 판결이 실시권자에게 전면적인 침해소송을 강제 진행할 수 있도록 허가할 것이라는 우려와는 달리, 이러한 소송은 특허의 유효성 또는 특허에 대한 즉각적이고 실제적인(sufficient

90) Schaffer v. Weast, 546 U.S. 49 (2005).

91) Medtronic, 134 S.Ct. at 851 ("when an element of a claim 'can fairly be characterized as [an] affirmative defens[e],'the burden of proof'may be shifted to [the] defendants'"; id., at 60, 126 S.Ct. 528"'[T]he ordinary rule, based on considerations of fairness, does not place the burden upon a litigant of establishing facts peculiarly within the knowledge of his adversary'").

92) *Id.* at 851.

93) Megan M. La Belle, *"Reverse" Patent Declaratory Judgment Actions: A Proposed Solution for Medtronic*, 162 U. PA. L. Rev. Online 43, 52 (2013).

94) *Id.* at 52-53 ("Just as Medtronic was able to sue for declaratory relief notwithstanding the license, the defendants could have counterclaimed with a DJ suit of their own. Indeed, the Federal Circuit recognized this explicitly in Lang, holding that, as long as there's a justiciable controversy, a patentee's right to seek a declaration of infringement against a future infringer mirrors the right of a future infringer to seek a declaration of noninfringement against a patentee.").

immediacy and reality) 분쟁이 있을 때만 발생할 수 있다. 본 사건에서 MFV사는 Medtronic사에게 침해를 주장함으로써 이 분쟁을 시작했기에 그 증명책임이 특허권자에게 유리해야 할 설득력 있는 이유가 없다.[95]

## 마 소결

미국에서는 *Medtronic v. MFV* 판결이 확정되기 전부터 *Under Sea v. Dacor* 판례에 따라[96] 특허권 비침해확인소송에서도 특허권 침해의 증명책임은 해당 소송의 피고인 특허권자가 부담하였다.[97][98] 원고가 증명책임을 부담하는 일반 확인소송과 달리 특허권 비침해확인소송에서는 피고인 특허권자가 침해의 증명책임을 부담하는 것이다.[99] *Medtronic* 사건에서 CAFC가 비침해확인소송의 원고(침해염려자)에게 비침해 증명책임을 부담하게 한 것은 (유효한 실시계약이 존재하였다는 해당 사안의 특이성으로 인한 것이라는 점에도 불구하고) 부적절한 것이었다. 연방대법원이 CAFC의 판단을 뒤집고 침해의 증명책임을 특허권자가 부담하게 할 것이라는 예견도 있었다.[100] 최종적으로 대법원은 단순한 법적 논리(simple legal logic)

95) *Id.* at 851.

96) Under Sea Indus., Inc. v. Dacor Corp., 833 F.2d 1551 (Fed. Cir. 1987).

97) Peter J. Shurn III, Using Declaratory Judgments Offensively in Patent Cases—DJ JIVE, 3 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 1, Fall 2003, at 3 ("However, it is the declaratory judgment defendant who has the burden of proving patent infringement exists. That is, the burden of proving patent infringement is on the patentee, regardless of who brings the lawsuit.").

98) Megan M. La Belle, supra, at 54 ("It is well established that patent owners bear the burden of proof on infringement and that the declaratory posture of the suit does not alter that burden. That a patent owner may be unable to counterclaim for present infringement in certain situations does not justify an exception to these rules. *MedImmune* held that all declaratory judgment actions should be treated equally, and *Medtronic* will now provide the Supreme Court with the opportunity to remind the Federal Circuit of this guiding principle.").

99) Peter J. Shurn III, supra, at 10 ("The burden is on the declaratory judgment defendant--the patentee--to prove infringement. Things are backwards, with the proponent of the action--the plaintiff--not bearing the burden of proof in respect to the merits of the non-infringement issues contented in the plaintiff's pleadings.").

100) Brianna Strange, *Medtronic v. Boston Scientific: Allocating the Burden of Proof in*

에 따라 특허권 침해의 증명책임은 특허권자에게 있다는 것은 100년 이상 전부터 확립되어 왔고 확인소송에서 그 증명책임이 전환될 수 없다고 판단하였다. 또한 혹자는 "증명책임은 부정하는 자가 아니라 긍정하는 자에게 있다(Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat)"는[101] 유서 깊은 격언에 따라 미국 대법원이 증명책임을 판단하였다고 평가되기도 하였다.[102] 약 80년의 법선례, 실용적 고려 및 공공정책을 고려하면 *Medtronic* 판결은 피할 수 없었다는 것이다.[103] 일각에서는 특허권자는 실시권자가 특허권을 침해했다고 주장한 후 침해를 증명할 준비가 되어 있어야 하기에, 침해소송에서 특허권자가 증명책임을 부담하는 것은 무리한 것이 아니며, *Medtronic* 판결로 인해 특허권자가 어느 경우든 침해의 증명책임을 부담하여야 하므로 실시권자를 향한 침해주장은 더 신중해져야 한다고 논평하였다.[104]

---

*Declaratory Judgment Actions for Patent Non-Infringement*, 9 Duke J. Const. L. & Pub. Pol'y 42, 58 (2013) ("The Federal Circuit's decision in *Medtronic* improperly gives the declaratory judgment plaintiff-licensee *Medtronic* the burden of proving non-infringement. In a declaratory judgment action for non-infringement, the plaintiff-licensee is necessarily at risk for infringement liability. The plaintiff in this instance should not bear the burden of disproving what they are impliedly accused of doing because this allocation of the burden does not comport with congressional intent or the procedural nature of declaratory judgments. To remedy the situation, the Supreme Court will likely reverse the Federal Circuit and hold the burden of proving infringement remains with the patent holder.").

101) The burden of proof lies upon him who affirms, not him who denies.

102) Sorin G. Zaharia, *Burden of Proof in Medtronic: The Federal Circuit's Idiosyncratic Patent Jurisprudence Vetoed, Again*, 30 Berkeley Tech. L.J. 777, 777 (2015) ("Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. In line with this time-honored maxim, the United States Supreme Court held in *Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC* that in a declaratory judgment action filed by a licensee denying infringement, the patent owner (the nominal defendant) retains the burden of proof for showing infringement.").

103) *Id.* at 805 ("While the Court's 'simple legal logic' partly relies on a historical quirk, the result in *Medtronic* was unavoidable in view of eighty years of legal precedent, practical considerations, and public policy.").

104) Heather Scruggs, *Burden of Proof in Declaratory Judgment Actions Between Patentee and Licensee Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC*, *134 S. Ct. 843 (U.S. 2014)*, 33 Corp. Couns. Rev. 143, 144 (2014) ("As stated by the Supreme Court, a patentee usually bears the burden of persuasion in an infringement action. Because a patentee must be ready to prove infringement after accusing a licensee of infringing on a patent, it is not unreasonable to expect the patentee to do the same in a situation

## 4 중국의 특허권 비침해확인소송에서의 증명책임 법리

### 가 특허권 비침해확인소송의 배경 및 관련 규정

중국에서는 비침해확인소송이 비교적 늦게 도입되었고 지재권 비침해 확인소송의 기능은 피경고인에게 권리자로부터 침해경고를 받았으나 권리자가 제소권을 행사하지 않은 장기간 불안 상태로부터 보호하는 일종의 사법구제 방법을 제공하는 것으로, 근본 목적은 권리자의 경고 남발을 규제하고 안정적인 시장운영 질서를 유지하는 것으로 해석하고 있다.[105]

2002년 7월 12일 최고인민법원은 〈최고인민법원의 쑤저우룽바오바이오엔지니어링공업회사(이하 롱바오사)와 쑤저우랑리푸건강제품유한공사(이하 랑리푸사) 특허권비침해확인 분쟁사건에 대한 답변〉을[106] 통하여 비침해확인소송의 개념을 명확히 정의하였다. 해당 문건은 "중화인민공화국 민사소송법 제108조 및 제111조의 규정에 의하여 조건에 부합하는 기소는 인민법원이 이를 수락해야 한다. 이 사건에서 피고 랑리푸사는 원고 롱바오사의 제품을 판매하는 대리점(经销商)에 원고의 제품이 특허권 침해가 의심된다는 서한을 송달하였고 대리점에서 원고의 제품 판매를 중단하여 원고의 이익에 침해를 가하여 원고는 이 사건과 직접적인 이해관계가 있으며 명확한 피고가 있고 구체적인 소송 청구, 사실과 이유가 있으며 법원이 민사소송을 접수하는 범위에 포함되어 있고 접수법원은 관할권이 있기에 인민법원은 사건을 접수해야 한다. 이 사건에서 원고가 법원에 소송을 제기한 목적은 단지 피고의 침해행위 주장에 대하여 법원에서 자신이 특허권을 침해하지 않음을 확인하도록 청구하는 것일 뿐, 피고의 행위가 침해행위라고 주장하며 침해책임을 추궁하는 것은 아니다."라고 답변하였다. 이 문건 이후, 지방법원에서 특허 관련

---

like this. ... Now that patentees know they will be responsible for proving infringement in either instance, perhaps they will be slower to accuse licensees of infringement.").

105) 杨志祥，龙龙，钟慧英，论知识产权确认不侵权之诉，学术论坛，2012 年第1期，2012，180页.

106) 《最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》(2001) 民三他字第4号 (2013년 4월 8일 폐지,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》로 대체).

비침해확인 사건을 접수하고 심리하기 시작하였다.

2010년 1월 1일부터 시행된 〈최고인민법원의 특허권 침해분쟁사건 심리의 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석〉의[107] 제18조는 비침해확인소송의 요건에 대하여 규정하였는바, 그 요건은 (1). 권리자가 피경고인(被警告人) 또는 이해관계인에게 침해경고장 발송; (2). 피경고인 또는 이해관계인은 침해 경고를 받은 후 권리자를 상대로 침해 경고를 철회하거나 소권을 행사하도록 서면으로 독촉; (3). 권리자가 합리적인 기한 내에 침해경고를 철회하지 않고 제소도 하지 않는 것이다. 이로부터 특허권을 침해하지 않는다는 확인을 위한 소의 접수조건이 명확해지기 시작했다. 저작권, 상표권 등 기타 지재권 확인소송의 기소 요건도 해당 해석문건의 규정을 참조하여 적용하였다.

2021년부터 시행된 〈최고인민법원의 지재권 민사소송 증거에 관한 여러 규정〉의[108] 제5조는 위의 해석규정을 참조하여 지재권 비침해 확인소송에서 원고의 증명책임을 명확히 하였다. 그 규정에 의하면 지재권 비침해확인소송을 제기하는 원고는 다음과 같은 사실을 입증하여야 한다. 첫째, 피고가 원고에게 침해경고장을 발송하거나 원고에게 권리침해신고 실행; 둘째, 원고가 피고에게 소권을 행사하도록 독촉장 발송, 독촉시간 및 송달시간; 셋째, 피고가 합리적인 기한 내에 기소를 하지 않은 것이다. 동 규정 제2조는 당사자는 자기의 주장에 대하여 증거를 제공하여 증명하여야 한다고 명시하여 "주장하는 자가 입증"한다는 민사소송의 원칙을 고수하고 있다.

## 나 비침해확인소송에서의 침해의 증명책임

사법실무상, 비침해확인소송의 대부분 판례는 중국 민사소송법 제67조 규정의[109] "주장하는 자가 입증"하는 원칙에 따라 비침해확인소송의 원고에게 비침해의 증명책임을 부담하도록 하고 있다. 2021년 최고인민법원 판례에서 법원은 "특

107) 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21号).

108) 《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》.

109) 《中华人民共和国民事诉讼法(2021)》第六十七条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据.

허권 비침해확인소송에서 확인대상 제품이 특허권 권리범위에 속하는지 여부는 원고가 증명책임이 있다"고 판시하였다.[110] 원고가 제시한 증거가 판사에게 확인대상 제품이 해당 사건 등록특허를 침해하지 않는다는 확신을 주지 못할 경우, 원고는 일반적으로 패소하게 된다.

하지만 일부 판례에서는 원고의 증명책임을 완화시키고 있다. 2019년 산동성 특허권 비침해확인 분쟁사건에서,[111] 항소심 법원은 "원심 원고는 제품이 확인대상 특허발명을 침해하지 않았음을 증명하기 위해'GPES 경질 발포 복합 플라스틱 보온판의 공식 및 제조 공정(GPES硬质泡沫复合塑料保温板的配方及制备工艺)을 제출하고 관련 감정 기관의 감정을 받았으며, 감정의견은 원심 원고의 제품과 그 제조 방법이 확인대상 특허발명과 동일하지 않다는 것이다. 원심 피고는 원심 원고가 생산한 본사건 관련 제품이 확인대상 특허발명을 침해했다고 주장하지만, 원심 원고의 구체적인 침해제품을 증명하지 못하였으며 항소심 재판에서도 관련 침해제품을 제시한 적이 없다고 인정하였다. 그러므로 원심 피고는 이 사건에서 원심 원고의 특정 침해제품을 입증하지 못하였고 해당 사건의 경고장이 주장한 침해제품을 제공하는 증명책임은 원심 피고가 부담하여 비침해확인소송의 심사 범위를 확정해야 하며 그러지 아니한 경우, 원심 피고/특허권자가 불리한 결과를 부담해야 한다."고 판시하였다. 이 판례에서는 비침해확인소송의 피고에게 특허발명을 침해한 구체적인 제품에 대한 증명책임을 부담하도록 요구하여 원고의 증명책임이 어느 정도 완화되었다.

2011년 절강성 특허권 비침해확인 분쟁사건에서,[112] 항소심 법원은 "특허권자인 피고가 원고에게 서한을 발송하여 원고가 허가 없이 확인대상 특허발명과 완전히 동일한 제품을 생산·판매하여 확인대상 특허발명을 침해했다고 주장하였기에 피고가 침해행위에 대한 증명책임을 부담하여야 하며 … 원고는 확인대상 특허발명에 대한 선사용권을 충분히 입증하였고 … 피고는 원고의 제품이 선사용권 주장 제품이 특허발명 권리범위와 동일하지 않다고 판단되면 그에 상응하는 증명책임을 부담하여야 한다. … 피고는 이 사건에서 원고의 침해행위를 입증할 어떠한 증거도

110) 最高人民法院, (2021) 最高法知民终1350号.
111) 山东省高级人民法院, (2019)鲁民终584号.
112) 浙江省高级人民法院, (2011) 浙知终字第204号.

제시하지 않았다."는 의견으로 원고 승소의 원심유지 판결을 내렸다. 이 사건에서 항소심 법원은 특허권자가 권리침해 성립의 증명책임을 부담하여야 한다는 입장이고, 원고가 이미 선사용권 주장을 뒷받침할 만한 일정한 증거가 있는 경우, 선사용권 주장 권리범위가 특허발명의 권리범위와 동일하지 않는 증명책임을 피고에게 분배하여 선사용권 성립에 대한 원고의 증명책임을 어느 정도 완화하였다.

2022년에 수정한 〈최고인민법원의 중화인민공화국민사소송법 적용의 해석〉의 제91조 규정은[113] 적극적인 사실을 주장하는 당사자가 증명책임이 있다는 기본원칙을 명확히 하였고 동법 제91조 제1항의 "법률관계의 존재를 주장하는 당사자는 당해 법률관계를 발생시킨 기본사실에 대하여 증명책임을 부담한다"는 규정에 따라 지재권의 비침해확인소송의 침해사실의 증명책임은 침해사실이 존재한다고 주장하는 피고(특허권자)가 부담하여야 한다는 견해들이 증가하고 있다.

## 다 소결

현재 중국은 법규정상 지재권 비침해확인소송에서 침해여부의 증명책임에 대한 명확한 규정이나 해석이 없기에 그 증명책임의 배분에 대해 두 가지 견해가 있는데, 하나는 민사소송법 제67조의 규정에 따라 원고가 자신의 '비침해 사실'에 대하여 증명책임을 부담하여야 한다는 것이고, 다른 하나는 소극적 확인소송에서의 증명책임 분배원칙에 근거하여 사실이 존재하지 않음을 입증하는 것이 사실의 존재보다 훨씬 더 어렵기에 피고(특허권자)가 원고와 피고 사이에 침해의 법률관계가 성립된다는 것을 증명하여야 한다는 것이다. 그러나 실무상, 지재권 비침해확인소

113) 〈최고인민법원의 중화인민공화국민사소송법 적용의 해석(2022)〉 제91조: 인민법원은 다음과 같은 원칙에 따라 주장·증명책임의 부담을 확정하여야 하지만 법률에 따로 규정된 경우는 제외한다. (1) 법률관계의 존재를 주장하는 당사자는 당해 법률관계를 발생시킨 기본사실에 대하여 주장·증명책임을 부담하여야 한다. (2) 법률관계의 변경, 소멸 또는 권리가 방해를 받았다고 주장하는 당사자는 당해 법률관계의 변경, 소멸 또는 권리가 방해를 받은 기본사실에 대하여 주장·증명책임을 부담하여야 한다. (《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释（2022修正）》, 第九十一条: 人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担， 但法律另有规定的除外：(一) 主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；(二) 主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人， 应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。).

송에서 침해여부의 증명책임을 대부분 비침해 사실을 주장하는 원고에게 부담하도록 하고 있다.

## 5 오스트리아의 (특허권) 권리범위확인심판에서의 증명책임 법리

오스트리아의 민사소송법(Zivilprozessordnung, ZPO) 제228조는 확인소송에 대하여 규정하고 있는바 법률요건을 충족하면 적극적 또는 소극적 확인소송을 제기할 수 있고 그 규정은 다음과 같다. “원고에게 해당 법률관계, 권리 또는 문서의 진위를 법원의 결정으로 조속히 확인할 법률상 이익이 있는 경우, 법률관계 또는 권리의 존재 또는 부존재를 확인하거나, 문서의 진위여부 확인을 청구하는 소송을 제기할 수 있다.”[114] 오스트리아 최고법원(Oberster Gerichtshof, OGH)은 확인소송의 절차적 목적은 분쟁 중인 법률관계를 명확히 할 필요가 있다고 법률제도가 인정하는 경우, 더 이상의 분쟁을 피하거나 향후 결정에 유용한 근거를 마련하기 위해 법률 상황을 명확히 하는 것이고 소극적 확인소송의 목적은 양 당사자에게 해로운 상황을 종료하고 법적 불확실성 원인인 피고의 법률추정을 방지하며 상대방이 추정하는 권리를 증명하거나 포기하도록 강제하도록 하는 것이다.”고 판시하고 있다.[115]

114) Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilprozessordnung §. 228. Es kann auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder Rechtes, auf Anerkennung der Echtheit einer Urkunde oder Feststellung der Unechtheit derselben Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass jenes Rechtsverhältnis oder Recht oder die Urkundenechtheit durch eine gerichtliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

115) OGH 10Ob47/20i, "Rechtliche Beurteilung 2. Prozessökonomischer Zweck der Feststellungsklage ist es, die Rechtslage dort zu klären, wo ein von der Rechtsordnung anerkanntes Bedürfnis nach Klärung strittiger Rechtsbeziehungen besteht, sei es, um weitere Streitigkeiten zu vermeiden, sei es, um eine brauchbare Grundlage für weitere Entscheidungen zu schaffen (RS0037422). Der Zweck der negativen Feststellungsklage ist primär, einen für beide Teile nachteiligen Schwebezustand zu beenden, eine Rechtsanmaßung des Beklagten als Ursache der Rechtsunsicherheit abzuwehren und den Gegner zu zwingen, das angemaßte Recht zu beweisen oder aufzugeben (RS0039109; RS0038974; Frauenberger-Pfeifer in Fasching/Konecny III/1 § 228 Rz 30 mwN)."

## 가 오스트리아의 특허청에 의한 권리범위확인 제도

오스트리아의 확인심판 제도는 한국의 권리범위확인심판 제도와 유사하다. 오스트리아의 확인심판은 어떤 객체가 해당 특허의 권리범위에 속하는지를 판단하는 것이고,[116] 해당 내용은 오스트리아 특허법 제163조에서 규정하고 있다. 오스트리아 특허법 제163조는 확인 구제(declaration relief)라는 제목 아래 제1항이 "업으로 제품을 제조, 판매하거나 방법을 사용하는 자 또는 그렇게 하려고 계획하는 자는 누구든지 특허권자 또는 전용실시권자를 상대로 특허청에 그 제품 또는 방법이 전적으로 또는 부분적으로 특허권의 권리범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다"고 규정하여 소극적 확인심판을 규율하고,[117] 제2항은 "특허권자 또는 전용실시권자는 특허청에 누군가가 산업적으로 어떤 물건을 생산, 판매를 위한 제공, 판매, 사용할 때 산업적으로 어떤 방법을 응용하거나 응용하려는 경우, 그 자를 상대로 그 물건 또는 방법이 전적으로 또는 부분적으로 특허의 권리범위에 속한다는 확인심판을 청구할 수 있다"라고 규정하여 적극적 확

116) Gerhard Friedl/Fritz Schönherr/Gottfried H. Thaler, Patent- und Markenrecht, Manzsche Verlags, 1979, 240 ("… beim Feststellungsantrag nach dem PatG hingegen ist Gegenstand des Verf nicht das Bestehen oder Nichtbestehen des PatRechts, sondern nur die Feststellung, ob ein bestimmter Gegenstand oder ein bestimmtes Verfahren unter ein bestimmtes Pat fällt oder nicht, anders ausgedrückt: wie weit das im PatRecht enthaltene Untersagungsrecht in einem bestimmten Fall geht."). ("…on the other hand, the subject of the proceedings is not the existence or non-existence of the patent right, but only the determination of whether or not a certain object or a certain process is covered by a certain patent, in other words: how far the right to prohibit contained in the patent right extends in a certain case.").

117) Patentgesetz 1970 ("§ 163 (1) Wer einen Gegenstand betriebsmäßig herstellt, in Verkehr bringt, feilhält oder gebraucht, ein Verfahren betriebsmäßig anwendet oder solche Maßnahmen beabsichtigt, kann gegen den Inhaber eines Patentes oder den ausschließlichen Lizenznehmer beim Patentamt die Feststellung beantragen, daß der Gegenstand oder das Verfahren weder ganz noch teilweise unter das Patent fällt.") . ("§ 163 (1) Anyone who manufactures an object commercially, puts it on the market, holds for sale or uses it, applies a process in an operational manner or intends to take such measures, can apply to the patent office against the holder of a patent or the exclusive licensee for a declaration that the object or the Procedure is not covered in whole or in part by the patent." (오스트리아 특허법의 영어 번역본은 https://ip-documents.info/2022/IP/AUT/22_7699_00_e.pdf 참조.)) .

인심판을 규율하고 있다.[118] 이러한 제도의 목적은 어떤 물건 또는 방법이 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 것이고, 산업활동 중에서 확인대상을 제조, 판매, 전시 또는 사용할 때 타인의 특허권을 침해하는지를 평가하는 것이 핵심이다.[119] 그러므로 확인심판은 결과적으로 침해소송의 제기를 방지하는 효과를 가져온다고 평가하기도 한다.[120]

## 나 증명책임

오스트리아의 민사소송법의 규정에 따르면, 원칙적으로 각 당사자는 자신이 제

118) Patentgesetz 1970 ("§ 163 (2) Der Inhaber eines Patentes oder der ausschließliche Lizenznehmer kann gegen jemanden, der einen Gegenstand betriebsmäßig herstellt, in Verkehr bringt, feilhält oder gebraucht, ein Verfahren betriebsmäßig anwendet oder solche Maßnahmen beabsichtigt, beim Patentamt die Feststellung beantragen, daß der Gegenstand oder das Verfahren ganz oder teilweise unter das Patent fällt."). ("§ 163 (2) The holder of a patent or the exclusive licensee may apply to the Patent Office for a declaration that the object or the process is against someone who manufactures, markets, sells or uses an object, uses a process or intends to take such measures falls under the patent in whole or in part.").

119) Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016, 427 ("Sinn und Zweck des Feststellungsverfahrens ist die Entscheidung, ob ein bestimmter Gegenstand oder ein bestitnmtes Verfahren unter ein Patent fällt oder nicht. Im Zuge des Feststellungsverfahrens ist zu beurteilen, ob ein Patenteingriff vorläge, falls der Feststellungsgegenstand betriebsmäßig hergestellt, in Verkehr gebracht, feilgehalten oder gebraucht (bzw zu diesen eingeführt oder besessen) würde."). (The purpose of the declaratory proceedings is to decide whether a certain object or a certain process is covered by a patent or not. In the course of the declaratory proceedings, it is to be assessed whether a patent infringement would exist if the subject matter of the declaration were manufactured, marketed, displayed or used (or imported or possessed) in the course of business.).

120) Peter Burgstaller, Österreichisches Patentrecht Kommentar, Wien: Verf. Medien und Recht, 2012, 245 ("Das Feststellungsyerfahren zielt auf die Herbeiführung einer Klärung, ob ein Gegenstand oder ein Verfahren unter ein Patent fällt oder nicht – Verletzungsklagen sollen dadurch möglichst hintangehalten werden."). ("The declaratory proceedings aim at clarifying whether an object or a process is covered by a patent or not – infringement suits are to be prevented as far as possible.").

기한 신청을 정당화하는 모든 사실적 주장(주장책임 - Behauptungslast)을 제시하고, 적절한 증거를 제출해야 하며(ZPO 제226조 제1항 및 제239조 제1항) 원고는 절차적 요건이 충족되었음을 증명해야 할 책임도 부담한다.[121][122]

민사특허권침해소송은 다른 일반 민사소송의 규정을 따르며, 그 증명책임도 마찬가지이다. 오스트리아 특허법 155조와 같이 특별히 피고에게로 증명책임을 전환한다는 규정이 없는 한, 사실을 주장하는 당사자가 그 사실에 대한 증명책

121) European Justice, Taking of evidence: Austria, 2023 ("In principle, each party is required to list all the factual claims justifying their application (burden of allegation --Behauptungslast) and to provide the appropriate evidence (Sections 226(1) and 239(1) of the Austrian Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung, ZPO)). Each party carries a burden of proof to ensure that the all the conditions of the rules favourable to it are met. Under normal circumstances, claimants must assert all the facts in support of their claim and defendants must assert all the fact in support of their objections. The claimant also bears the burden of proving that the procedural requirements are met." 〈https://e-justice.europa.eu/76/IT/taking_of_evidence?AUSTRIA&clang=en〉.

122) Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilprozessordnung §. 226. (1) Die mittels vorbereitenden Schriftsatzes anzubringende Klage hat ein bestimmte Begehren zu enthalten, die Thatsachen, auf welche sich der Anspruch des Klägers in Haupt- und Nebensachen gründet, im einzelnen kurz und vollständig anzugeben, und ebenso die Beweismittel im einzelnen genau zu bezeichnen, deren sich der Kläger zum Nachweise seiner thatsächlichen Behauptung bei der Verhandlung zu bedienen beabsichtigt. § 239. (1) Die nach § 230 Abs. 1 aufgetragene Beantwortung der Klage hat mittels vorbereitenden Schriftsatzes zu geschehen. Sie hat ein bestimmtes Begehren zu enthalten und, soweit der Klagsanspruch bestritten wird, Anträge gestellt und Einreden erhoben werden, die Tatsachen und Umstände, auf welche sich die Einwendungen, Anträge und Einreden der beklagten Partei gründen, im Einzelnen kurz und vollständig anzugeben sowie die Beweismittel, deren sich der Beklagte zum Nachweis seiner tatsächlichen Behauptungen bei der Verhandlung zu bedienen beabsichtigt, im Einzelnen genau zu bezeichnen. (오스트리아 민사소송법 제226조 제1항: 준비서면을 통하여 제기되는 소장에는 특정한 청구를 포함해야 하며, 원고의 주장 및 주장의 근거하는 사실들을 개별적으로 간결하고 완전하게 명시해야 한다. 또한, 원고가 자신의 사실적 주장에 대한 증명을 위해 변론에서 사용할 의도인 증거자료도 구체적으로 상세하게 명시해야 한다. 제239조 제1항: 동법 제230조 제1항에 따르면, 소장에 대한 답변은 준비서면을 통하여 이루어져야 한다. 이 준비서면에는 특정한 청구를 포함해야 하며, 원고의 청구를 항변하는 경우에는 신청을 하고 항변을 제기해야 한다. 피고의 이의, 신청 및 항변의 근거가 되는 사실과 사정을 개별적으로 간결하고 완전하게 명시해야 하며, 피고가 자신의 사실 주장에 대한 증명을 위해 변론에서 사용할 의도인 증거자료도 구체적으로 상세하게 명시해야 한다.).

임을 부담한다.[123][124]

적극적 확인심판의 청구인은 반드시 피청구인의 피동적법성(Passivlegitimation)을 증명하여야 한다.[125][126] 따라서 적극적 확인심판의 청구인은 특허권 침해소송에서의 원고와 같이 자신이 청구한 피청구인의 침해행위가 이미 일어났거나 일어날 우려가 있음을 증명할 책임이 있다.[127]

---

123) Sascha Salomonowitz, Global Patent Litigation : Austria, October 2008, at 29 ("Civil patent infringement litigation follows the same rules as other civil litigations. ... The parties have to present the facts on which they base their arguments and provide evidence for each fact. The general principle is of course that the party relying on a particular fact also has the burden of proof for this fact unless a burden of proof rule such as Section 155 Patent Act switches the burden of proof to the other party. According to Section 155 Patent Act any object produced according to a patented process is assumed to be using such process in case the result is the same (see 3.3). Hence defendant has to show that he uses a different process to overcome that assumption.").
〈http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi34/globalpat entlitigation/austria.pdf〉.

124) Gesamte Rechtsvorschrift für Patentgesetz 1970, § 155. Bei einem Patent für ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses gilt bis zum Beweis des Gegenteiles jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. ("Austrian Patent Law 1970, 155. In case of a patent for a process for the manufacture of a new substance, any substance with the same characteristics shall be regarded as having been manufactured according to the patented process until proof to the contrary.")

125) Guido Kucsko, Geistiges Eignetum (=Intellectual Property), MANZ Verlag Wien, 2003, 962 ("Der Feststellungswerber muss die maßgeblichen Tatsachen für die Passivlegitimation des Antragsgegners nachweisen."). ("The applicant for a declaratory statement must prove the relevant facts for the passive legitimacy of the defendant.").

126) Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016, 429("Bei einem positiven Feststellungsantrag hat der Antragsteller die Passivlegitimation des Belangten bzw die hiefür maßgeblichen Umstände nachzuweisen."). ("In the case of a positive application for a declaratory judgement, the applicant has to prove the passive legitimacy of the defendant or the relevant circumstances.").

127) Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016, 429("Damit ist der (positive) Feststellungswerber für die — erfolgte oder erst beabsichtigte — behauptete „Patentverletzung" de facto in derselben Weise beweispflichtig wie der Kläger im gerichtlichen Patentverletzungsverfahren;....."). ("Thus, the (positive) declaratory petitioner is de facto obliged to prove the alleged "patent infringement" - which has occurred or is only intended - in the same way as the plaintiff in the judicial patent infringement proceedings;.....")

## 6 일본의 부존재(비침해) 확인소송에서의 증명책임

### 가 상표권 부존재(비침해) 확인소송에서의 사례

원고가 상표권자를 대상으로 제기한 상표권침해금지부존재확인(商標権に基づく差止請求権不存在確認) 소송에서, 법원은 "피고가 원고에게 피고 상표권의 사용금지청구권을 가지려면 피고 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 피고 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부착하거나 지정상품에 관한 광고에 피고 상품과 동일한 표장을 부착하여 전시한 것 등에 대하여 피고가 주장·증명책임이 있다"고 설시하였다.[128] 권리자가 피고임에도 불구하고 권리자의 증명책임을 인정한 사례이다.

원고가 피고(특허권자)를 상대로 피고가 원고에게 "특허발명실시각서(発明の使用に関する覚書)"에 근거한 실시료지급청구권 및 특허권 침해의 손해배상청구권을 가지지 않는다는 채무부존재확인소송에서, 법원은 "채무부존재확인청구소송에서, 대상이 되는 채무의 발생 사유 사실은 피고가 주장·증명의 책임을 부담한다"고 설시한 후[129] 피고가 책임을 다하지 못하였다는 이유로 원고의 청구를 인용하였다.[130] 또 다른 상표 사건에서도 유사한 판결이 선고된 바 있다.[131]

---

128) 大阪地方裁判所平成２０年（ワ）第２１４９号("(4)そこで，被告が原告に対し被告商標権に基づき，原告標章の上記態様での使用の差止請求権を有するか否かについて検討する。被告が原告に対し上記差止請求権を有するというためには，被告商標の指定商品と同一又は類似の商品に被告商標と同一又は類似の商標を付し，あるいは，指定商品に関する広告に被告商品と同一の標章を付して展示するなどしたこと（商標法２５条，２条３項，３７条）について，被告に主張立証責任があるところ，…").

129) 東京地方裁判所平成２９年（ワ）第３３２２６号("債務不存在確認請求訴訟において、対象となる債務の発生原因事実は、被告が主張立証責任を負担する抗弁事実と解されるところ、…").

130) 앞의 판결, "当裁判所は、平成２９年１１月３０日、本件を書面による準備手続に付し、同日、被告に対し、平成３０年１月３１日までに、本件覚書に基づく原告に対する使用支払請求権及び本件特許権の侵害による原告に対する損害賠償請求権の各発生原因事実を主張、立証することなどを命じたが、被告は、同日までに、これらの主張立証をしなかった。"

131) 大阪地裁 平成１６年（ワ）第２３９８号; 債務不存在確認事件（本訴）平成１７年（ワ）第１８９１号 損害賠償請求事件（反訴）, "本件本訴は，債務不存在確認請求訴訟であり，本件商標権侵害行為によって被告が被った損害の額に関する主張立証責任は，本件反訴を提起するか否かにかかわらず，当初から被告が負っていたものである。".

### 나 특허권 비침해 확인소송

특허발명의 권리범위에 속하지 않는 경우, 제조판매방해금지 가처분 신청이나 금지청구권 부존재 확인소송을 제기할 수 있고, 선사용권이 있는 경우 금지청구권 부존재 확인소송이나 통상실시권 확인청구소송을 제기할 수 있다.[132] 균등침해가 주장되는 경우, 제1요건 내지 제3요건은 특허권자 측에서 주장·증명해야 한다는 점에 대해 학설상 이견이 없고, 최고재 판례해설도 같은 취지로 설명하고 있다. 제4요건 및 제5요건에 대해서는 학설상 견해가 일치하지 않은 가운데 최고재 판례해설은 제4설(소극적 요건 입증배분설)이[133] 타당하다고 하고 있지만, 제2설(적극적 요건 입증설)이[134] 다수설이다.[135]

## 7 영국의 (특허권) 비침해 확인제도 및 Opinion제도에서의 증명책임 법리

영국 법원에서는 특허와 관련하여 여러 가지 확인소송을 제기할 수 있고 그 확인소송에는 특허권 침해 또는 비침해 확인소송을 포함한다. 영국 특허법 제71조는 영국 지식재산청에 의한 확인 제도를 규정하고 있는데 이는 우리나라의 소극적 권리범위확인심판과 유사하다.

---

132) 김건형, "국제특허분쟁 가이드-일본편", 고분자 과학과 기술, 제23권 제6호, 한국고분자학회, 2012, 651면.

133) 김동준, 앞의 책, 191면("제4설(소극적 요건 입증배분설)은 제1요건 내지 제3요건에 대하여는 특허권자가 주장·입증책임을 부담하지만, 제4요건에 대하여는 주장책임과 입증책임을 분리하여 상대방이 특허출원시에 특정의 공지기술의 존재를 주장·입증하여 당해 공지기술과의 관계에서 제4요건의 비충족을 주장한 경우에는, 특허권자가 제4요건의 충족 (대상제품 등이 당해 공지기술과 동일 또는 통상의 기술자가 출원시에 이것으로부터 용이하게 추고할 수 있었던 것이 아닐 것)을 입증해야 하며, 제5요건에 대하여는 상대방이 대상제품 등에 있어서 다른 부분이 특허출원과정에서 보정 등에 의해 감축된 구성요건에 관한 것임을 주장·입증해야 한다(따라서 당해 공지기술로부터 용이하게 추고할 수 있었는지 여부가 분명하지 않은 경우에는 균등은 부정된다)는 견해이다.").

134) 김동준, 앞의 책, 191면("제2설(적극적 요건 입증설)은 제1요건 내지 제3요건에 대하여는 특허권자 측에서 주장·입증해야 하지만, 제4요건 및 제5요건에 대하여는 균등론의 적용을 배척하기 위한 항변사유로서 상대방이 주장·입증책임을 부담한다는 견해이다.").

135) 김동준, 앞의 책, 193면.

영국은 이미 특허청에 의한 비침해확인에 구속력을 인정하고 있다. 즉, 법원에 의한 비침해확인과 특허청에 의한 비침해확인은 동일한 효과를 가지는 것이다.[136]

## 가 영국의 특허청에 의한 비침해확인 제도

영국 법원에는 특허와 관련하여 여러 가지 다양한 확인을 청구할 수 있다. 그 확인에는 특허권 침해 또는 비침해 확인, 특허의 유효 또는 무효 확인, 표준특허의 필수성(essentiality) 확인, 자유실시기술 확인 등이 있다.[137] 또한 특허권 비침해 확인소송을 청구하면서 영국에서의 비침해는 물론 유럽 다른 국가에서의 비침해확인도 청구할 수 있다. 영국의 이러한 확인소송은 미국 연방법원에서의 확인소송(declaration action)과 유사한 것으로 생각된다. 그러나 이러한 확인소송 제도가 존재하는데도 불구하고 영국은 특허청에 비침해확인을 청구하는 제도를 부가적으로 두고 있다.[138] 영국 지식재산청의 비침해확인(declarations of non-infringement)은 신청인의 어떠한 행위가 특허권침해를 구성하지 않는다는 사실을 청장이 확인하여 주는 제도이며 법원에도 불복할 수 있다는 점에서 우리나라의 소극적 권리범위확인심판과 유사한 점이 있지만, 청장의 비침해 확인은 법원에 의한 확인(declaration)과 동일한 (기판력을 포함하는) 효력을 가진다.[139]

침해에 대한 증명책임을 특허권자 또는 전용실시권자가 부담하는 침해소송의 경우와 달리 비침해확인의 신청인이 비침해에 대한 증명책임을 부담한다.[140]

136) 정차호, 앞의 보고서, 28면.

137) Richard Miller et at., *Terrell on the Law of Patents* 17th ed., Sweet & Maxwell, 2011, at 807.

138) 정차호, 앞의 보고서, 17면.

139) 정차호, 앞의 보고서, 75-76면; Intellectual Property Office, “Manual of Patent Practice” Section 71(2) (“Subject to section 72(5) below, a declaration made by the comptroller under this section shall have the same effect as a declaration or declarator by the court.”).
〈https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-71-declaration-or-declarator-as-to-non-infringement〉.

140) 정차호, 앞의 보고서, 77면; Intellectual Property Office, “Manual of Patent Practice”Section 71 (“The burden of proving the absence of infringement rests, in my judgment, upon the plaintiff.”).

*Mallory Metallurgical v Black Sivalls* 사건에서 법원은 그 점을 명확하게 하였다.[141] 법원에 대한 청구사항이 특허 비침해, 무효 및 집행불가 등 다른 사항일지라도 청구 당사자가 증명책임을 부담한다.[142] 이러한 영국의 비침해확인소송에서의 원고 증명책임의 법리는 영연방국가인 뉴질랜드에서도 그대로 적용된다.[143]

## 나 영국의 비침해판정(Opinion) 제도

영국 특허법 제74A조가 규정하는 판정(Opinion) 제도에 근거하여 누구든지(anyone) 특허의 유효 및 침해에 대한 특허청의 판정을 구할 수 있다. 이해관계가 없는 제3자도 청구할 수 있다. 누구든지 또는 제3자에 의한 청구가 있는 경우 특허권자 및 전용실시권자는 대응할 수 있는 기회를 가진다. 판정의 대상이 되는 특허권의 존속기간이 만료된 경우에도 청구할 수 있고 판정 청구는 하나의 특허에 대하여만 이루어진다.[144] 하지만 이러한 특허청에 의한 판정은 법적 구속력을 가지지 않는다.[145] 특허청 심사관은 신청인이 제시한 주장을 평가하고 신청일로부터 3개

〈https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-71-declaration-or-declarator-as-to-non-infringement〉.

141) Mallory Metallurgical Products Limited v Black Sivalls and Bryson incorporated [1977] RPC 321, 345 ("…. the description must be sufficiently clear and precise to enable the court to declare that an article corresponding with the description would not constitute an infringement. The burden of proving the absence of infringement rests, in my judgment, upon the plaintiff. If there be lack of clarity or precision, the court is not in a position to grant the declaration sought").

142) Craig Turner, Daniel Byrne, Geoff Hussey and Mike Jennings, "At a glance: patent enforcement proceedings in United Kingdom", Lexology, "What are the burdens of proof for establishing infringement, invalidity and unenforceability of a patent? Any party seeking relief from the court has the burden of proof, whether that is for infringement, invalidity or otherwise. The standard to which that party must prove its case is on the balance of probabilities.", 〈https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=98281433-ceea-4af3-a079-23f9d5e3786e〉.

143) Arrow Pharmaceuticals (NZ) Limited v Sanofi-Aventis, High Court of New Zealand (9, 17 June 2008).

144) 정차호, 앞의 보고서, 19면.

145) Guidance_Opinions: resolving patent disputes, Intellectual Property Office, 2014("An opinion is not binding on you or others involved.") 〈https://www.gov.uk/guidance/opinions-resolving-patent-disputes〉.

월 이내에 구속력이 없는 판정을 한다. 그러므로 비침해판정에서 증명책임을 논하는 것은 적절하지 않지만 신청인의 제시한 자료가 결과에 크게 좌지우지 되기에 굳이 논한다면 신청인이 증명책임을 부담한다고 봐야 할 것이다.

## 8 독일의 확인소송의 증명책임 법리

독일의 민사소송법(Zivilprozessordnung, ZPO) 제256조는 확인소송(Feststellungsklage)에 대하여 규정하고 있다. 제1항은 "원고에게 해당 법률관계 또는 문서의 진위를 법원의 결정으로 조속히 확인할 법률상 이익이 있는 경우, 법률관계의 존재 또는 부존재를 확인하거나, 문서의 진위여부 확인을 청구하는 소송을 제기할 수 있다."고 규정하고 있다.[146]

독일연방대법원 판결에 의하면, "독일 절차법에서는 소극적 확인소송에서도 분쟁의 주제는 존재 여부를 다투는 실체적 청구 자체이므로 청구의 존재에 대한 각 당사자의 증명책임을 변경하지 않는다는 원칙이 적용되므로 독일법의 일반적인 원칙과 마찬가지로 청구인이 청구를 주장하기 위해 청구의 존재를 입증해야 한다면, 해당 청구인은 소극적 확인소송에서 피고인 경우에도 청구의 존재를 입증해야 한다. 따라서 소극적 확인소송에서 당사자 역할의 전환은 증명책임의 분배에 영향을 미치지 않는다."고 판시하고 있다.[147] 독일연방대법원은 각

146) ZPO § 256 Feststellungsklage (1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

147) BGH NJW 1993, 1716 ("Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, daß jede Partei diejenigen Tatsachen beweisen muß, aus denen sie ihren Anspruch herleitet. Den Anspruchsteller trifft daher die Beweislast für alle rechtsbegründenden Tatsachen (BGHZ 113, 222 (225) = NJW 1991, 1052 = LM HWiG Nr. 5). In welcher Parteirolle er sich dabei befindet, ist gleichgültig. Bei einer Leistungsklage muß daher der Kläger ebenso wie bei einer positiven Feststellungsklage die tatsächlichen Voraussetzungen seines Anspruchs beweisen. Gelingt ihm dieser Beweis nicht, muß die Klage abgewiesen werden. Grundsätzlich nichts anderes gilt bei der negativen Feststellungsklage, mit der der Kläger einem Anspruchsberühmen des Beklagten

당사자가 자신의 주장을 뒷받침하는 사실을 증명하여야 한다는 일반원칙에 따라서 소극적 확인소송은 피고의 주장을 반박하는 소극적 확인을 청구하는 소송이므로 다른 규정이 별도로 적용되지 않고 원고는 피고가 특정 사실에 근거한 청구를 인지하고 있다는 사실만 증명하면 되고 피고가 자신의 주장사실에 대하여 증명책임을 부담하여야 한다.[148] 지재권 보유자가 경고장(warning letter)을 발송한 후, 제기되는 비침해확인소송에서 지재권 보유자가 침해사실을 증명해야 한다는 법리가 정립되어 있다.[149]

## 9 결 론

### 가 소극적 권리범위확인심판에서의 증명책임

특허권 침해소송에서는 원고인 권리자가 피고가 특허발명을 무단으로 실시하였다는 점, 즉 침해사실을 증명할 책임을 부담한다. 일반적인 민사소송에 적용되는 "주장하는 자가 증명한다"의 원칙을 따른 법리이다. 적극적 권리범위확인심판에서도 그러한 증명책임 법리가 그대로 적용될 것이다. 침해염려자가 청구인이 되고 특허권자가 피청구인이 되는 소극적 권리범위확인심판에서의 증명책임은 누가 부담하는 것이 타당한가? 특허법원 2016허4818 판결 및 2006허2295 판결은 그 심판에서도 "주장하는 자가 증명한다"의 원칙에 따라 청구인이

---

entgegentritt. Hier muß der Feststellungskläger lediglich beweisen, daß sich der Beklagten eines Anspruchs aufgrund eines bestimmten Lebenssachverhalts berühmt (BAG, NJW 1985, 221). Dagegen obliegt dem Anspruchsteller in der Rolle des Feststellungsbeklagten der Beweis derjenigen Tatsachen, aus denen er seinen Anspruch herleitet, denn auch bei der leugnenden Feststellungsklage ist - wenn auch mit umgekehrten Parteirollen - Streitgegenstand der materielle Anspruch, um dessen Bestehen oder Nichtbestehen gestritten wird. Nach ständiger Rechtsprechung ist deshalb die Umkehr der Parteirollen bei der negativen Feststellungsklage auf die Darlegungs- und Beweislastverteilung ohne Einfluß.")

148) 〈http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/njw93_1716.htm〉.

149) BGH, June 20, 2017 - VI ZR 505/16.

확인대상이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음을 증명하여야 한다고 설시한 바 있다. 본 논문은 그 판결의 타당함에 대해 점검하였다.

그 점검을 위하여 소극적 권리범위확인심판이 존재하는 오스트리아 및 영국의 제도를 먼저 살펴보았고, 또, 소극적 권리범위확인심판과 상응하는 특허권 비침해확인소송에서의 미국, 중국, 일본, 독일의 상응 법리를 분석하였다. 그 분석의 결과는 다음 표와 같이 요약, 정리된다. 다음 표는 소극적 권리범위확인심판 또는 비침해확인소송에서 증명책임을 누가 부담하는지에 대하여는 주요국의 법리가 양분되어 있음을 잘 보여준다.

〈주요국의 비침해확인소송에서의 증명책임 법리〉

| 구분 | 비침해확인소송의 원고 또는 소극적 권리범위확인심판의 청구인이 증명책임을 부담 | 권리자인 피고 또는 피청구인이 증명책임을 부담 |
|---|---|---|
| 우리나라 | 특허 권리범위확인심판<br>특허법원 2016허4818 판결<br>특허법원 2006허2295 판결 | 대법원:<br>금전채무부존재확인소송;<br>유치권부존재확인소송;<br>배당이의소송 |
| 미국 | 특허권 비침해확인소송<br>Medtronic 사건 CAFC | 특허권 비침해확인소송<br>Under Sea 사건 CAFC<br>Medtronic 사건 연방대법원 |
| 중국 | 특허권 비침해확인소송<br>最高人民(2021)最高法知民终1350号 | 특허권 비침해확인소송<br>山东省高级(2019)鲁民终584号<br>浙江省高级(2011)浙知终字第204号 |
| 일본 | - | 특허권 비침해확인소송<br>東京地方平成29年(ワ)第33226号상<br>표권 비침해확인소송<br>大阪地方平成20年(ワ)第2149号<br>大阪地裁平成16年(ワ)第2398号 |
| 영국 | 특허청 비침해확인 제도<br>Manual of Patent Practice § 71.04<br>Mallory v Black [1977] RPC 321 | - |
| 독일 | | 교통사고 책임부존재확인소송<br>BGH NJW 1993, 1716<br>지재권 비침해확인소송<br>BGH VI ZR 505/16 |

## 나 권리자(피청구인) 증명책임 부담의 타당성

소극적 권리범위확인심판은 책임의 위협을 받는 당사자가 자신의 행위가 타인의 특허권리범위에 속하는지 여부의 확인을 청구함으로써 장래의 침해소송의 위험을 피할 수 있게 도와주는 제도이다. 따라서 소극적 권리범위확인심판의 유용성은 침해소송을 방지하는 기능에서 빛을 발한다. 그 점이 증명책임의 분배에서도 고려되어야 한다.

소극적 권리범위확인심판에서의 확정심결이 의미를 가지기 위해서는 소극적 권리범위확인심판에서도 권리자(피청구인)가 청구인이 특정한 확인대상이 권리범위에 속함(침해)을 증명하게 하는 것이 타당하다. 만약, 그러하지 않고 소극적 권리범위확인심판에서 청구인이 확인대상이 권리범위에 속하지 않음(비침해)을 증명하게 하는 경우 후속 특허권침해소송에서 동일한 소송물에 대해 다시 다투어야 하는 비경제가 초래된다. 그러한 비경제를 피하기 위해서라도 권리자(피청구인)가 청구인의 행위가 권리범위에 속함을 증명하게 하는 것이 타당하다.

비경제의 초래에 대해 부가 설명한다. 소극적 권리범위확인심판에서 청구인이 증명책임을 부담하는 법리를 가정하면, 그 청구인이 확인대상이 권리범위에 속하지 않음을 증명하지 못하는 경우, 해당 청구는 기각된다. 그러나, 그 기각으로 인하여 해당 확인대상이 권리범위에 속한다는 사실이 증명된 것은 아니다. 그러므로, 그 뒤의 특허권침해소송에서 권리자(소극적 권리범위확인심판에서의 피청구인)가 피고(소극적 권리범위확인심판에서의 청구인)의 행위가 권리범위에 속한다는 사실을 별도로 증명하여야 한다. 이는 하나의 사실에 대하여 특허심판원과 특허권침해소송에서의 법원이 중복으로 심리하게 한다. 애초, 소극적 권리범위확인심판이 지양한 침해소송 방지 또는 간편화의 기능이 발휘되지 못하는 것이다.

피청구인(권리자)이 증명책임을 부담하는 법리를 가정하면, 그 피청구인(권리자)이 확인대상이 권리범위에 속함을 증명하는 경우에는 후속 특허권침해소송에서 침해 여부는 다툴 필요도 없이 바로 손해배상액을 산정할 수 있을 것이다. 만약, 피청구인(권리자)이 확인대상이 권리범위에 속함을 증명하지 못하는 경우에는 후속 특허권침해소송은 (기판력이 인정되는 경우) 각하되거나, (기판력이 인정되지 않는

경우) 의미가 없게 된다. 즉, 소극적 권리범위확인심판이 후속 특허권침해소송을 방지하거나 간편하게 하는 기능이 작동되는 것이다.

이러한 증명책임 법리는 특허무효의 증명에서도 유사하게 적용된다. 속하지 않음을 증명하지 못한 것이 속함이 증명된 것은 아니듯이, 특허무효가 증명되지 못한 것이 특허유효가 증명된 것은 아니다. 특허는 유효한 것으로 추정되고, 특허무효를 주장하는 자가 그 추정을 복멸하기 위하여 무효사유를 증명해야 한다. 그 주장자가 해당 무효사유의 증명에 실패한다고 하여도 유효함이 증명된 것이 아니다. 단지, (해당 제시된 증거에서는) 무효하지 않음이 증명된 것이다.[150]

앞에서 설명된 바와 같이, 소극적 권리범위확인심판에서의 청구인(침해염려자)이 속하지 않음에 대해 증명책임을 부담하게 하면 소극적 권리범위확인심판의 유용성이 떨어지게 된다. 미국 *Medtrodic v. MFV* 사건에서도 Breyer 대법관은 증명책임의 특허권자가 아닌 상대방으로의 전환은 특허발명의 권리범위에 대한 불확실성을 야기하고 소송을 불필요하게 복잡하게 할 수 있어 확인소송의 취지에 반하며, 확인소송의 절차를 원고에게 불리하게 만들 수 있으므로 증명책임은 원고가 아닌 피고인 특허권자가 부담하여야 한다고 설시하였다.[151] 또한 확인소송의 최종성(finality)에도 영향을 미치므로 당사자에게 즉각적이고 확정적인 법적 권리를 제공한다는 확인소송의 목적도[152] 달성하지 못할 것이라고 설명하였다.

소극적 권리범위확인심판의 피청구인(권리자)에게 증명책임을 부여하는 법리를 가정하면, 피청구인이 권리범위에 속함(침해)을 증명하지 못하는 경우, 해당 심판부는 속하지 않음(비침해)을 확인하는 심결을 선고할 것이다. 이런 경우, 확정심결의 기판력이 인정되지 않더라도 권리자가 침해소송을 제기할 가능성은 아주 희박

150) Michael A. Ritscher, Albert Tramposch, Thomas J. O'Connell & Lisa Barons, *The Status of Dual Path Litigation in the ITC and the Courts: Issues of Jurisdiction, Res Judicata and Appellate Review*, 18 AIPLA Q.J. 155, 173-74 (1990) ("A finding against one challenging a patent is not a determination of validity, but is rather, as the Federal Circuit has identified, that the 'one attacking validity has not overcome the statutory presumption of validity', i.e. that the patent is 'not invalid'".) (citing Stevenson v. Sears, Roebuck & Co., 713 F.2d 705, 711 (Fed. Cir. 1983)).

151) Medtronic, 134 S.Ct. at 849-850.

152) to provide "an immediate and definitive determination of the legal rights of the parties."

할 것이다. 기판력이 인정되면, 해당 침해소송은 각하될 것이다. 피청구인(권리자)이 권리범위에 속함(침해)을 증명하는 경우, 해당 소극적 권리범위확인심판에서 특허권 침해를 확인하게 되는 것이다. 이후, 권리자가 침해금지명령, 손해배상을 청구하는 이행의 소인 침해소송을 제기할 시, 소극적 권리범위확인심판의 기판력이 인정되는 경우, 해당 침해소송에서 피고(청구인) 비침해 주장을 할 수 없고 손해배상액 등 문제에 대하여서만 다투게 될 것이다. 소극적 권리범위확인심판의 기판력이 불인정되는 경우, 해당 침해소송에서 피고의 비침해주장은 가능하나 해당 다툼은 소극적 권리범위확인심판에서 다루었던 권리범위에 속함 여부와 실질적으로 동일하여 중복으로 심리하게 될 것이다.

따라서 소극적 권리범위확인심판의 기판력이 인정되지 아니하면, 동일한 문제에 대한 중복 심리는 피할 수가 없다. 다만, 소극적 권리범위확인심판의 기판력이 인정되는 경우, 해당 심판에서 권리자(피청구인)가 증명책임을 부담하면 쟁점이 된 문제에 대하여 최종적으로 해결하는 결과를 가져오며 당사자들의 권리에 대하여서도 해결을 하는 확인의 결정을 하여 권리범위확인심판의 유용성이 더욱 높아질 것이다.

〈청구인(침해의심자)에게 증명책임을 부여하는 경우〉

| 구분 | 심판결과 | 침해소송 단계 |
|---|---|---|
| 증명 성공 | 속하지 않음 =비침해 | 기판력 인정→ 특허권자의 침해소송 제기 불인정(각하) |
| | | 기판력 불인정→ 특허권자의 침해소송 제기 가능(중복 심리) |
| 증명 실패 | 속하지 않음이 아님≠속함(침해) | 특허권자가 침해소송을 제기하는 경우, 특허권 침해에 대하여 새롭게 증명(중복 심리) |

〈피청구인(특허권자)에게 증명책임을 부여하는 경우〉

| 구분 | 심판결과 | 침해소송 단계 | |
|---|---|---|---|
| 증명 성공 | 속함=침해 | 기판력 인정→ 침해소송 단계(침해금지명령, 손해배상 등 청구)에서 피고(청구인) 비침해 주장 불가 | |
| | | 기판력 불인정→ 침해소송 단계에서 피고 비침해 주장 가능(중복 심리) | |
| 증명 실패 | 속하지 않음=비침해 | 침해 소송 無 | 기판력 인정→ 특허권자 침해소송 제기 불가(각하) |
| | | | 기판력 불인정→ 특허권자가 침해소송을 제기할 가능성은 현실적으로 매우 낮음 |

## 다 균등침해에서의 증명책임

특허권 침해는 문언침해와 균등침해로 나누어진다. 소극적 권리범위확인심판에서 특허권자(피청구인)가 문언침해의 증명에 실패하면 균등침해를 주장할 수도 있다.

특허발명이 (예를 들어) (A+B+C)의 구성요소로 이루어진 경우, 소극적 권리범위확인심판의 특허권자(피청구인)는 확인대상의 구성요소 중 하나인 대체기술(대체요소)이 균등요소에 해당한다고 주장하게 된다. 대체요소가 균등요소에 해당하는지 여부는 다음의 5가지로 판단된다.

〈균등침해 판단기준〉

| 구분 | 요소 | 내용 |
|---|---|---|
| 적극적 요건 | 균등 1요소 | 동일한 과제해결원리 |
| | 균등 2요소 | 실질적으로 동일한 작용효과 |
| | 균등 3요소 | 치환 용이성 |
| 소극적 요건 | 균등 4요소 | 자유실시기술의 항변 |
| | 균등 5요소 | 의식적으로 제외된 범위 |

### (1) 적극적 요건의 증명책임

문언속함이 인정되지 않은 경우, 권리자는 균등속함을 주장할 수 있따. 그 주장에서 균등 5가지 요소 중 적극적 요건에 해당하는 3가지 요소를 증명하여야 할 것이다. 특허발명의 구성요소와 비교되는 대체요소가 동일한 과제해결원리를 가졌다는 점, 실질적으로 동일한 작용효과를 가진다는 점 및 치환 용이성을 증명할 수 있을 것이다. 그러한 증명이 악마(부존재)의 증명에 해당하지도 않고, 증명하면 할수록 권리자에게 불리하지도 않다. 학설도 균등의 적극적 요건에 대하여는 권리자가 증명책임을 부담하여야 한다고 보고, 김동준 교수님도 그 학설에 동의한 바 있다.[153]

153) 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012, 419면.

### (2) 소극적 요건의 증명책임

확인대상이 자유실시기술에 해당한다는 점(균등 4요소) 및 균등범위가 의식적으로 제외된 범위에 해당한다는 점(균등 5요소)은 특허권자가 아닌 청구인이 증명하는 것이 타당하다. 청구인에게 유리한 사항은 청구인이 증명하는 것이 타당하다. 특허권자가 출원 절차 중 해당 균등범위를 의식적으로 제외하지 않았다는 점(부존재)을 증명하게 하는 것이 타당하지 않다. 청구인이 그의 출원이력(서류철)을 바탕으로 그 의식적 제외를 증명하는 것이 가능하며, 타당하다.

적극적 권리범위확인심판 사건에서 대법원은 균등 5가지 요소 중 소극적 요건에 해당하는 균등 4요소 및 균등 5요소에 대하여는 특허권자가 아닌 상대방이 주장·증명하여야 한다고 설시한 바 있다.[154] 적극적 권리범위확인심판을 청구한 특허권자가 증명책임을 부담하는 것이 원칙이나, 그 두 요소는 상대방(피청구인)에게 유리한 사항이므로 상대방이 증명하는 것이 타당하므로, 대법원은 증명책임법리의 기본원칙의 예외를 허용한 것이다. 적극적 권리범위확인심판에서도 피청구인이 균등침해의 소극적 요건에 대해 증명책임을 부담하여야 한다면, 소극적 권리범위확인심판에서는 청구인이 증명책임을 부담하는 것이 더 타당하다.

종합적으로, 소극적 권리범위확인심판에서 특허권자(피청구인)가 권리범위에 속함의 문언침해를 증명하여야 하고, 그 증명에 실패하여 균등침해를 주장하는 경우, 적극적 요건에 해당하는 3가지 요소는 특허권자(피청구인)가 증명책임을 부담하고 소극적 요건에 해당하는 2가지 요소는 청구인이 증명책임을 부담하는 것이 타당하다고 본다.

154) 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후1240 판결("원고가 실시하는 3개의 케이블을 채택한 장치는 이 사건 특허발명에서 종래의 기술이라고 하여 의식적으로 제외한 구성이고, 또한 확인대상발명은 공지기술인 비교대상발명으로부터 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 위 양 구성은 균등관계에 있지 않다는 주장이나. 이는 균등론의 적용을 배제하기 위한 요건으로서 확인대상발명을 실시하는 자가 주장·입증하여야 할 것이다.").

# 참 고 문 헌

## [국내 문헌]


1. 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012.
2. 안철상·조병구·정기상, 실무중심 요건사실: 민사소송, 서울 : 유로, 2019.
3. 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 2023.
4. 김건형, "국제특허분쟁 가이드-일본편", 고분자 과학과 기술, 제23권 제6호, 한국고분자학회, 2012.
5. 백경일, “증명책임의 분배와 위험영역설에 관한 비판적 고찰 - 독일에서의 논의를 참고하여 -”, 법학논총, 제19권 제3호, 조선대학교 법학연구원, 2012.
6. 이미옥, “특허사건의 주장·입증책임”, 재산법연구, 제27권 제3호, 한국지식재단연구원, 2011.
7. 임병웅·윤선희, "권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정에 관한 소고", 지식재산연구, 제4권 제3호, 한국지식재산연구원, 2019.
8. 조민석, “공해소송에 있어서 입증책임 - 입증경감을 중심으로 -”, 토지법학, 제27권 제2호, 한국토지법학회, 2011.
9. 정차호, "특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임", 행정법연구, 제36호, 사단법인 행정법이론실무학회, 2013.
10. 정차호, "권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안 연구", 특허청, 2015.
11. 전현철, "조세소송에 있어서 주장책임과 증명책임에 관한 고찰", 원광법학, 제35권 제3호, 원광대학고 법학연구소, 2019.
12. 정하중, “행정소송에 있어서 직권탐지주의와 입증책임”, 고려법학 제64호, 고려대학교 법학연구원, 2012.

13. 최선웅, “행정소송에서의 변론주의와 직권탐지주의: 행정소송법 제26조를 중심으로”, 서울대학교 법학박사학위논문, 2004.

[외국 문헌]

1. Peter J. Shurn III, "USING DECLARATORY JUDGMENTS OFFENSIVELY IN PATENT CASES—DJ JIVE", 3 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 1, Fall 2003.
2. Brianna Strange, "MEDTRONIC v. BOSTON SCIENTIFIC: ALLOCATING THE BURDEN OF PROOF IN DECLARATORY JUDGMENT ACTIONS FOR PATENT NON-INFRINGMENT", 9 Duke J. Const. L. & Pub. Pol'y Sidebar 42, 43, 2013.
3. Sorin G. Zaharia, "Burden of Proof in Medtronic: The Federal Circuit's Idiosyncratic Patent Jurisprudence Vetoed, Again", 30 Berkeley Tech. L.J. 777, 2015.
4. Megan M. La Belle, "Reverse" Patent Declaratory Judgment Actions: A Proposed Solution for Medtronic, 162 U. PA. L. Rev. Online 43, 54, 2013.
5. Heather Scruggs, "Burden of Proof in Declaratory Judgment Actions Between Patentee and Licensee Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC, 134 S. Ct. 843 (U.S. 2014)", 33 Corp. Couns. Rev. 143, 2014.
6. 杨志祥，龙龙，钟慧英，论知识产权确认不侵权之诉，学术论坛, 2012 年第1期，2012.
7. Guido Kucsko, Geistiges Eignetum (=Intellectual Property), MANZ Verlag Wien, 2003.
8. Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz

2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016.

9. Craig Turner, Daniel Byrne, Geoff Hussey and Mike Jennings, "At a glance: patent enforcement proceedings in United Kingdom", Lexology.

10. Michael A. Ritscher, Albert Tramposch, Thomas J. O'Connell & Lisa Barons, The Status of Dual Path Litigation in the ITC and the Courts: Issues of Jurisdiction, Res Judicata and Appellate Review, 18 AIPLA Q.J. 155, 1990.

11. Richard Miller et at., Terrell on the Law of Patents 17th ed., Sweet & Maxwell, 2011.

12. Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016.

13. Sascha Salomonowitz, Global Patent Litigation : Austria, October 2008.

14. European Justice, Taking of evidence: Austria, 2023.

15. Peter Burgstaller, Österreichisches Patentrecht Kommentar, Wien: Verf. Medien und Recht, 2012.